



**Unidad Administrativa Especial Agencia del  
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC**

**SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO/LEY 1437 DE 2011**

El artículo 84 de la Ley 1437 de 2011, establece que el Silencio Administrativo Positivo se configura *“Solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones legales especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva. Los términos para que se entienda producida la decisión positiva presunta comienzan a contarse a partir del día en que se presentó la petición o recurso. El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocación directa en los términos de este Código”*.

**SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO/SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL**

*En términos constitucionales se puede definir la figura del silencio administrativo como una herramienta que el legislador ha dispuesto para que el ciudadano pueda: i) hacer valer sus derechos ante la administración de justicia, en el caso del silencio administrativo negativo, por cuanto no puede quedar indefinidamente a la espera de una respuesta por parte del este estatal encargado de resolverla, hecho que hace necesario crear un mecanismo para que pueda acudir ante la misma administración recurriendo el acto ficto o ante la jurisdicción o, ii) ver satisfechos sus derechos ante la omisión de la administración, en el caso del silencio administrativo positivo, en la medida en que el mutismo de aquella concreta en su cabeza un derecho. Sobre las opciones que tiene el ciudadano cuando opera el silencio administrativo negativo ha dicho esta Corporación en forma reiterada: “..., el administrado puede optar por acudir a la jurisdicción o por esperar una respuesta efectiva de la Administración, sin que esta última opción, que es un desarrollo del derecho de petición, pueda acarrearle consecuencias adversas, como sería la de que a partir del momento previsto para la operancia del silencio administrativo se contabilice el término de prescripción o de caducidad de la respectiva acción”. De esta manera, si bien se podría considerar que en el marco del Estado Social de Derecho la administración está en la obligación de dar respuesta oportuna, clara, concreta y de fondo a las solicitudes presentadas por los ciudadanos, en donde la consagración de una ficción sobre la negativa o aceptación de las peticiones pueden ser percibida como contraria a los postulados de la función pública y el respeto por los derechos fundamentales, si se tienen en cuenta que uno de los fines del Estado es garantizar los derechos consagrados en la Constitución y facilitar la participación de todos en las decisiones que lo afectan, artículo 2 constitucional; la Sala no duda en afirmar que esas presunciones resultan un instrumento adecuado para garantizar, entre otros, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, vulnerados por la omisión de la administración al no responder oportunamente los requerimientos elevados por los ciudadanos. Ficción que en los términos de nuestro ordenamiento no exime a la administración de absolver la solicitud, porque el derecho de petición sólo se satisface cuando el Estado profiriere respuestas claras, precisas y de fondo<sup>1</sup>.*

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Dependencia:</b>              | Subdirección de Investigaciones Disciplinarias     |
| <b>Número del Proceso:</b>       | 1704-01-2015-083                                   |
| <b>Número y fecha del fallo:</b> | Resolución 17317-00020 del 21 de noviembre de 2016 |
| <b>Asunto:</b>                   | Fallo de primera instancia                         |

<sup>1</sup> Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 52 (parcial) de la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

**RESOLUCIÓN No. 17317-00020**  
**21 de noviembre de 2016**

**POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO**  
**No. 1704-01-2015-083**

**1. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO**

Una vez concluida la investigación disciplinaria tramitada en el proceso administrativo disciplinario número 1704-01-2013-083, el Subdirector Técnico de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, procede a proferir fallo de primera instancia, conforme a las exigencias del artículo 170 de la Ley 734 de 2002 y de acuerdo a lo que sigue.

**2. IDENTIDAD DEL INVESTIGADO**

XXXXX, identificada con la cédula de ciudadanía número XXXXX, vinculada a la DIAN como Supernumeraria desde el 07 de octubre de 2014, hasta el 03 de julio del 2014, en planta temporal desde el 04 de julio de 2014 a la fecha. Actualmente se encuentra desempeñando el cargo de Analista II Código 202 Grado 02 en la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la Unidad Administrativa Especial DIAN. Para el periodo del 14 de octubre de 2014, fecha de los hechos se desempeñaba en la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la Unidad Administrativa Especial DIAN.

XXXX, identificado con la cédula de ciudadanía número XXXXX. Su vinculación con la entidad lo es como supernumerario desde el 16 de julio de 1998 hasta el 31 de diciembre del año 2011, empleado de planta temporal desde el 02 de enero de 2012 a la fecha. Actualmente se desempeña en el cargo de Analista III código 203 Grado 03 y ubicado en la Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control Registro de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la Unidad Administrativa Especial DIAN, misma labor desplegada para la fecha de los hechos.

**3. HECHOS**

Fueron puestos en conocimiento mediante oficio No 100215362-12784 de fecha 05 de enero de 2005 suscrito por la Jefe de la Coordinación de Notificaciones de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá y dirigido al Subdirector de Gestión de Control Disciplinario de la DIAN, reportando la omisión del envío de la notificación de la Resolución No. 10067 del 06 de octubre de 2014, a través de la cual se confirmó la Resolución No. 1.03.241-201-644-0-0648 del 25 de junio del mismo año, que impuso sanción a la Agencia de Aduanas Move Cargo S.A. Nivel 1, en cuantía de \$505.832.857, por incurrir en la infracción consagrada en el numeral 2.6 del artículo 485 del Decreto 2685 de 1999.

De acuerdo con la comunicación referida, el 06 de octubre de 2014 se recibió la resolución para su notificación y para el 07 del mismo mes y año se remitió a la Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registro para elaborar las comunicaciones de rigor, donde el acto administrativo llegó físicamente a la Coordinación de Notificaciones sin culminar el proceso de la notificación, producto de lo cual la publicidad del acto se agotó tan sólo hasta el 02 de diciembre de 2014, generándose el silencio administrativo positivo respecto de la Resolución No. 10067 del 6 de octubre de 2014, habida cuenta que el término para notificar el acto que resolvía el recurso de reconsideración interpuesto el 23 de julio de 2014 vencía el 23 de octubre del mismo año.

**4. CARGO UNICO FORMULADO**

XXXXX, en su condición de analista II Código 202 Grado 02 de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la Unidad Administrativa Especial de la DIAN, es autora y responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria descrita en el numeral 35 del artículo 48 del CDU **"Dar lugar a la configuración del Silencio Administrativo Positivo"**, con

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

ocasión de la no notificación en término, del recurso de reconsideración resuelto mediante resolución No. 10067 del 06 de octubre de 2014 de la Dirección Seccional de Aduanas Bogotá, el cual fuera interpuesto contra la resolución No. 1-03-241-201.644-0-0648 del 25 de junio de 2014, por medio de la cual la División de Gestión de Liquidación de la Dirección seccional de Aduanas de Bogotá, sancionó con multa de \$505.832.857 a la sociedad XXXXX.

La notificación no se gestionó en el término previsto en el artículo 515 del Decreto 2685, por cuanto la investigada no tramitó en el aplicativo Notificar el estado recibido del acto administrativo 10067, para así permitir continuar con el proceso por el GIT de la Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control Registro, a cargo del funcionario XXXXX, esto es, generar la planilla de correspondencia para ante la empresa de mensajería, no obstante haberle enviado en físico la planilla con el respectivo acto.

XXXXX, en su condición de analista III código 203 Grado 03, en la Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control Registro de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la Unidad Administrativa Especial DIAN, como autor responsable de la infracción disciplinaria descrita en el numeral 35 del artículo 48 del CDU **"Dar lugar a la configuración del Silencio Administrativo Positivo"**, con ocasión de la no notificación del recurso de reconsideración, resuelto mediante resolución No. 10067 del 06 de octubre de 2014 de la Dirección Seccional de Aduanas Bogotá, recurso interpuesto contra la resolución No. 1-03-241201.644-0-0648 del 25 de junio de 2014, por medio de la cual la División de Gestión de Liquidación de la Dirección seccional de Aduanas de Bogotá, sancionó con multa de \$505.832.857 a la sociedad Agencia de Aduanas de Move Cargo S.A.

Hecho que ocurrió por no haber gestionado en el término previsto en el artículo 515 del Decreto 2685 de 1999, la respectiva notificación de la decisión a los interesados, cuando no obstante haber recibido en físico la planilla número 602 de fecha 7 de octubre de 2014, con el acto administrativo a notificar de parte de la Coordinación de Comunicaciones, a cargo de la funcionaria Ana Paola Cleves, al verificar el funcionario el acto en el aplicativo Notificar, no aparecía recibido el acto, lo cual le impidió generar la planilla de correspondencia, así como usar el aplicativo para hacer la corrección en el sistema, tan solo lo hizo en forma verbal.

#### 1. ARGUMENTOS DE DEFENSA: VERSIÓN LIBRE, DESCARGOS Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

##### 5.1 DE LA VERSION LIBRE DE CARLOS MAURICIO MOLINA GUTIERREZ<sup>1</sup>,

Sobre los hechos investigados señaló:

**"Efectivamente como consta en la planilla 602, ésta fue recibida por mí el 07 de octubre de 2014, porque es parte del proceso que hago de todos los documentos que me llegan para el aplicativo Notificar, que es recibir la planilla, verificar que los datos coincidan tanto con el oficio como en la planilla de remisión, y si están correctos, generar la planilla de correspondencia; y si hay error generar la planilla de devolución. Cuando procedí a verificar la información de que estuviera recibida por parte de la Coordinación de Comunicaciones en el aplicativo Notificaciones, ésta no fue cargada al aplicativo Notificar por la funcionaria de notificaciones encargada para eso, área encargada de recibirla en el aplicativo Notificar y posteriormente me remiten la planilla para que la Coordinación de Notificaciones Oficiales genere la planilla de Correspondencia.**

**Procedí a verificaren el aplicativo notificar si ésta había sido recibida, pero no se encontró en el sistema recibida, nipara generar planilla de Correspondencia, nipara generar planilla de devolución. Como todas las devoluciones se hacen en el aplicativo notificar, aquíno hay manera de generar devolución escrita por planilla de devolución que arroja el aplicativo, razón por lo cual procedía a devolverla de manera física a la funcionaria Ana Paola Cleves para que fuera recibida en el aplicativo notificar por la Coordinación de Notificaciones Oficiales y Control de Registros. La planilla fue devuelta a la Coordinación de Notificaciones, pero nunca retornó a la Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registro, para darle trámite al envío del documento, ya eso esto fue solamente posible de realizar hasta el22de enero de2015..."**

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

Allega a la diligencia el histórico del trámite de la resolución, donde se evidencia que la funcionaria la recibió el 07 de octubre de 2014, pero únicamente en el sistema se pudo generar planilla de correspondencia, solo hasta el 22 de enero del 2015, afirmando que es la fecha en que la funcionaria Ana Paola la envía en original y físico para darle trámite y genera la planilla de correspondencia.

Enseña que, al devolver la planilla física a la Coordinación de Notificaciones, ella fue recibida por la funcionaria Paola Cleves, quien manifestó que la ingresaría y la devolvería nuevamente a la Coordinación para darle el trámite correspondiente, lo cual nunca fue realizado.

El señor XXXXX encuentra extraño que los oficios de notificaciones hayan sido enviados sin numeración interna o consecutivo de la Coordinación de Notificaciones, con fecha del 2 de diciembre de 2014, directamente en la ventanilla de correspondencia interna, obviando el trámite en la ventanilla del aplicativo Notificar, de acuerdo a los pantallazos allegados.

Sobre el particular, anexa dos oficios con registro de consecutivo de fechas 2 de diciembre de 2014, sin numeración interna, dirigidos al representante legal de la Agencia de Aduanas Move Cargo y al Señor Carlos Eduardo Valencia Cardona, remitiendo para su notificación del acto administrativo, expedido el 6 de octubre del año 2014<sup>2</sup>, suscrito por la funcionaria XXXXX, sin mencionar allí las razones de la mora.

Allega así mismo el disciplinado, copias de email(s) sobre ejemplos de los errores o inconsistencias entre lo remitido virtualmente y lo recibido en físico por parte de la oficina de Notificaciones, con copia de los respectivos pantallazos.

En otro correo, con fecha ilegible, indica en mensaje: Acto pendiente de notificación administrativa 17-12- 2014, emitido por XXXXX, sin poderse apreciar a quien va dirigido y CC a. En su contenido se tiene textualmente sobre los hechos investigados:

***"... Con respecto al acto 10067 del 6 de octubre, si éste hubiera sido recibido estaría en el sistema listo para ser planillado, pero el mismo no figura por ningún lado. Por lo tanto, si existiera de que por error mío no hubiera generado la planilla de correspondencia para realizar el respectivo envío, éste estaría presente en el sistema para generar la planilla correspondiente" (sic)***

## 1.2 DE LA VERSION LIBRE DE ANA PAOLA CLEVEZ VILLARRAGA.

Refirió que, como funcionaria de notificaciones le corresponde notificar los actos administrativos, en ese momento proferidos por la Subdirección de Recursos Jurídicos, procedimiento en el cual cuenta con cinco días para notificar.

Sobre el caso objeto de investigación expuso que fue recibido el 6 de octubre de 2014 por la Coordinación de Notificaciones, ese mismo día fue devuelto por medio de planilla de remisión No. 602, al área de comunicaciones oficiales, tal como se aprecia en la planilla que está en el expediente. En lo concerniente a la planilla, afirmó que iba anexa con un solo acto administrativo, era el acto número 10067, del 6 de octubre de 2014, con dos direcciones a notificar. Adujo que la planilla no contenía más actos y que la misma fue recibida para el posterior proceso de notificaciones por parte de la Coordinación de Comunicaciones oficiales y Control de Registros, y por parte de ellos nunca se manifestó la devolución del acto administrativo, por lo que señaló que le generó confianza y seguridad su notificación.

Agregó que, en diciembre de 2014 se enteró que tal acto administrativo no tenía la guía de notificación, por lo que la solicitó a comunicaciones, sin que le dieran respuesta.

Informó además que, debido al derecho de petición presentado por los interesados sobre la notificación de acto administrativo, se apresuró a buscar la notificación, sin que Comunicaciones Oficiales hallara el envío de la notificación, por lo que procedió a surtir la notificación el día 03 de diciembre de 2014, para cumplir así con la función en el área de notificaciones. Posteriormente ingresó la información en enero de 2015 con una planilla manual por no hallarse en el sistema, lo que impedía notificar y surtir la ejecutoria normalmente. Finaliza aseverando que tanto el control



POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

interno de su procedimiento y de la inclusión del sistema nada tiene que ver, ni afecta a terceros.

### 5.3. DE LOS ALEGATOS DE DEFENSA

#### 5.3.1 Alegato presentado por el defensor de XXXXX

1. - Inicia solicitando se tenga en cuenta la razón de ser del derecho, señalado que por mandato constitucional se debe preservar el debido proceso, las garantías de los sujetos procesales, para lo cual cita al hombre de las leyes FRANCISO DE PAULA SANTANDER, la constitución de 1986 y cita la sentencia de Constitucionalidad C 1061 de 2006 y T969 sobre las garantías constitucionales, referidas a la legalidad, publicidad el derecho a la defensa contradicción, derecho de presunción de imparcialidad, non bis in ídem, de cosa juzgada, entre otros.

2. - Aduce que en el proceso se atendía un procedimiento diferente y luego se atendió la falencia que se presentaba.

3. - Reitera su planteamiento sobre los fines del pliego de cargos, con base en la Sentencia de Magistrado Diego Tunes de febrero de 1999 No. 0099, expediente 1709, sobre las funciones del pliego de cargos, el cual concreta las bases de la responsabilidad del funcionario. Los cargos según la jurisprudencia citada, deben ser claros, suficientes, ciertos, pertinentes, así como lo señala la ley 734 de 2002, como igualmente la carga de la prueba recae en la administración. En su desarrollo hace un análisis del pliego de cargos, referidos a la valoración probatoria., citando apartes de su contenido.

En el decurso de su intervención deja saber que le preocupa la aplicación de la sana crítica ya que el pliego de cargos se aleja de esa exigencia legal, artículo 141 del código disciplinario, la apreciación integrar de las pruebas, por lo que afirma que esa apreciación subjetiva del pliego de cargos no tiene sustento, de allí la razón de su recusación.

4. Se refiere a los escenarios en que se sucedieron los hechos, los Grupos de la DIAN designados al proceso de notificación, la de Comunicaciones y Notificaciones, cada uno con sus funciones.

5. Indicó que aprendió en la investigación, que en aras de que sea más expedito el proceso se acude a la tecnología, por lo que para la época de los hechos se empezó a implementar ello, existiendo una resolución que entraba en esa fecha y un memorando que señaló que no se aplicaba por qué tenía falencia.

6.- Su análisis probatorio los direccionó a los siguientes medios probatorios:

a. El correo electrónico de XXXXX de fecha 2 de diciembre de 2014, en el cual la funcionaria indaga por la planilla de correspondencia para verificar la notificación del acto administrativo.

b. - El documento de la planilla de entrega física del acto administrativo 10076, en el cual afirma es la absoluta constancia de entrega y de recibido con la firma de XXXXX, documento consecutivo que lo hace el sistema y por lo tanto asevera que Paola sólo era un segundo filtro que tenía que revisar circunstancia de forma.

De la devolución, como lo señala XXXXX, no hay prueba de ello.

Cita a Jairo Parra Quijano respecto a los diferentes medios de pruebas, para insistir que no hay ninguno que confirme tal devolución.

c. Respecto del Testimonios de XXXXX, dejó saber que no se puede limitar el actuar al aplicativo, hay que notificar el día señalado, se trabaja con términos, por lo que no se puede arriesgar, se estaba hablando de más de quinientos millones de pesos que la DIAN perdió.

d. La visita administrativa a la oficina de tecnología debió partir del memorando o manual donde se establecía que había errores en el sistema, un memorando que dejaba en suspenso una normatividad, pero eso no impedía a Carlos Molina hacer las comunicaciones.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

**r**

El ingeniero XXXXX allí afirmó, para el mes de octubre del 2014 había inconsistencias que se mostraba con las solicitudes de la mesa de ayuda, como tipo de impuestos, tipos de entrega, éste último fue enmendado recientemente, hecho no considerado por el pliego de cargos.

Insiste en que allí se estableció que había una mora en la entrega de las guías, lo cual ocurrió a mediados de octubre y que había muchos líos como lo indicó la testigo XXXXX. Reconoce el defensor que ésta testigo deja conocer la obligatoriedad en las dos áreas, al hacer el respectivo registro en el aplicativo Notificar, invitando a ver el procedimiento que fue "regalado" en la audiencia. Cita la definición del tratadista Jairo Parra Quijano respecto del testimonio de oídas, para referirse que no entiende lo afirmado en el pliego de cargos respecto de la diferencia entre la entrega físico y la virtual.

e. - No entiende cómo se puede explicar que hubo confianza y que su representada incurrió en un acto omisivo.

f. - Afirma que contrario a las pruebas adelantadas antes de la audiencia, las recibidas en ella si arroja conclusiones, a saber:

.- La declaración de XXXXX reitera la entrega del acto administrativo de forma física el 7 de octubre de 2014, así como que Molina debió enviar una comunicación a Ana Paola Cleves si había un impedimento que no permitía continuar con el trámite.

.- El testimonio de XXXXX indica a folio 75 de su inicial exposición, cómo es el procedimiento, el cual inicia con el área de emisión del acto administrativo, la Subdirección de recurso jurídicos, asentando que eso si es prueba; luego llega al grupo de notificaciones oficiales para luego mandarlo a notificaciones.

Esgrime que, la testigo afortunadamente ilustró al señalar que, cuando hay problemas en el grupo de comunicaciones oficiales, como cuando no coincide la dirección se debe devolver advirtiendo la observación; por lo tanto, en el rol de su asistida no hubo ninguna devolución y dicho grupo tenía la tranquilidad de la entrega del acto con base en el acta de recibido, por lo que culminó el proceso allí.

.- El testimonio de XXXXX, dejó saber que es una mala práctica devolver el acto sin dejar rastro. Esgrimiendo la defensa "meras subjetividades su señoría..." (sic)

Agrega que ésta testigo ayudó mucho, "Dijo que seguramente en el trámite había un problema y se podía solucionar". Hay términos legales que cumplir, 5 días, de ellos se sabe que en notificaciones se recibió el 6 y el 7 se le dio el trámite.

Finaliza su intervención señalando que se requiere fallar con certeza, pide se le absuelva a su defendida atendiendo la duda ya que no se probó la responsabilidad objetiva, no se pudo concluir que hubo omisión, no se probó, el despacho no tiene la certeza de la comisión del hecho y por ello se debe exonerar del cargo a XXXXX, ya que ella no dio lugar al silencio administrativo positivo.

### 5.3.2 Alegato presentado por la defensora de XXXXX

Inició haciendo un detallado recuento de los hechos bajo una línea de tiempo, luego de lo cual precisa la adecuación típica de la conducta disciplinable que por los hechos se ha endilgado a los aquí disciplinados, artículo 48 numeral 35 de la Ley 734 de 2002, "Dar ***lugar a la configuración del silencio administrativo positivo.***"

Respeto de los cargos enrostrados a su asistido, la defensa considera que no existe la ilicitud sustancias respecto de su asistido, estructurando su argumentación en dos consideraciones:

En la primera consideración (I) se analizará lo afirmado por el despacho en el pliego de cargos frente a que su defendido ***"no gestiona el acto de comunicación oficial como exige los procedimientos administrativos"***; segundo el carácter ***"inexcusable"*** el hecho que el acto a notificar no apareciera

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

***"registrado en el aplicativo notificar por parte de la funcionaría de notificaciones"***

La defensa estimó que el proceder de Carlos Molina en palabras del despacho ***"a mera devolución de acto en forma física sin soporte de la novedad"*** y la ***"desatención ...al no verificarse hiciera en debida forma el procedimiento y así cumplir con su labor asignada."*** se encuentra cobijado frente a lo que la jurisprudencia y la doctrina ha denominado principio de confianza legítima. Para desarrollar este argumento en defensa de la actitud asumida por el señor MOLINA haciendo referencia a la sentencia de 2da Instancia Radicación 12655 citada por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal el 30 de noviembre de 2006 en la que se puede leer:

***"la violación del deber de cuidado objetivo se evalúa siempre dentro de un ámbito situacional determinado, es decir, por medio de un juicio de la conducta humana en el contexto de relación el cual se desempeñó el acto, y no en el aislamiento de la fealdad de lo que este hizo o dejó de hacer"***

Al respecto textualmente señalo: "En este sentido, téngase en cuenta que la finalidad del señor XXXXX, al recibir y firmar la planilla 602, enviada únicamente en forma física, omitiendo el envío a través del Aplicativo Notificar por la Coordinación de Notificaciones, el 7 de octubre de 2014, no fue diferente a la de querer cumplir oportunamente con las funciones que le habían sido asignadas conforme a los numerales primero, tercero y noveno de su manual de funciones<sup>4</sup> y que en cumplimiento de su deber confió en el trabajo desarrollado por sus compañeros.

Sobre esto último, es decir, el principio de confianza, la Corte en la sentencia que se viene de citar, de manera puntual señaló:

***"...en orden a examinarla violación del deber de cuidado objetivo, rige la regla de confianza, elaboración doctrinaria que parte del hecho de la intersubjetividad permanente del ser humano, razón por la cual, quien participa de una actividad riesgosa, compleja o delicada, en la medida que actúa diligente y cuidadosamente, tiene derecho a confiar en que los demás partícipes harán lo propio." ...se insiste en que el principio de confianza no otorga derechos sobre los demás, simplemente obedece a una regla de la experiencia que razonablemente rige la interacción humana, motivo por el cual solo el cumplimiento del individuo en lo que le obliga y es su aporte al trabajo mancomunado, lo habilitara para confiar y no verse afectado por la malicia o despreocupación de los demás partícipes."***

Siguiendo la misma línea de pensamiento, la jurisprudencia citada referencia la sentencia de 3 agosto de 2005 dictada dentro del Radicado 22901 que señala:

***"a determinación de la efectividad del principio de confianza en un ámbito de interrelación está guiada por la apreciación racional de las pautas que la experiencia brinda o de las concretas condiciones en que se desenvuelve una actividad u organización determinada, porque son elementos que posibilitan señalar si una persona, al satisfacer las reglas de comportamiento que de ella se esperan, está habilitada para confiar en que el dolo o la culpa de los demás que interactúan en el tráfico jurídico no la van a afectar."***

Ahora bien, frente a la acusación hecha por la Jefe de Coordinación de Notificaciones, XXXXX, de incurrir en una ***"malpráctica"*** por realizar ***"la devolución en forma física sin soporte de la novedad"***, y que según señala el despacho de haber obrado en ***"desatención. ...al no verificar se hiciera en debida forma el procedimiento y así cumplir con su labor asignada."***, el señor XXXXX no estaba en condiciones de asumir un comportamiento diferente al que observo y obligatoriamente debía confiar en sus compañeros de trabajo, en la medida que como lo manifestó en repetidas ocasiones el señor XXXXX, en su ampliación de testimonio, es costumbre, es decir, constituía una práctica frecuente adoptada por los miembros de las oficinas de Notificaciones y Comunicaciones hacerse requerimientos verbales frente a los casos en los que, como el que nos ocupa, se omite ingresar un acto administrativo al Aplicativo Notificar. Para que el despacho pueda corroborar que la anterior afirmación no falta de ninguna forma a la verdad, hago una remisión al minuto 10:40 al minuto 12:58 y del 16:27 al 25:04 en el que el señor XXXXX confirma lo anteriormente relacionado.

Adicionalmente la defensa desea anotar que la mencionada ***"mala práctica"*** además de ser una costumbre construida sobre la confianza y buena fe que existía entre las dos oficinas para la época de los hechos, el uso obligatorio del sistema del Aplicativo Notificar no le daba otra opción a mi

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

defendido, en la medida que, como quedo establecido por el Ingeniero XXXXX, experto en el uso del Aplicativo, si el acto a notificar no aparece en el sistema, la Coordinación de Comunicaciones no puede generar ningún tipo de planilla y este error debe ser corregido por la Coordinación de Notificaciones para que se pueda seguir dando tramite a los actos administrativos.

Así las cosas la defensa estima que el señor XXXXX actuó cobijado por el principio de confianza legítima que, como manifiesta la sentencia citada, se determina guiándose **"por la apreciación racional de las concretas condiciones en que se desenvuelve una actividad u organización determinada"**, en el caso objeto de estudio, el construido a partir de la práctica recurrente entre las dos oficinas implicadas de hacerse requerimientos verbales con el fin de corregir errores frente a la omisión de utilizar el Aplicativo Notificar. Esta situación género que mi defendido, contrario a la calificación de **"mala práctica"** haya obrado satisfaciendo, como señala la jurisprudencia, **"las reglas de comportamiento que de ella se esperan"** o que lo habilitaba a **"confiar en que el dolo o la culpa de los demás que interactúan en el tráfico jurídico no la van a afectar."**

Finalmente concluyó con base en esta argumentación que "... la defensa solicita, la exoneración de toda responsabilidad disciplinaria a su defendido XXXXX, por la ausencia de ilicitud sustancial y por lo tanto se ordene el archivo definitivo de la investigación".

6. CONSIDERACIONES DE INSTANCIA:  
RAZONES DE LA DECISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS EN QUE SE BASA  
6.1. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA:

Este Despacho es competente para proferir el fallo de primera instancia dentro de la presente investigación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con las previsiones del Decreto 4173 del 3 de noviembre de 2011.

En atención a lo ordenado en el Artículo 142 de la Ley 734 de 2002, se establece imperativamente que no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado, cuya apreciación debe corresponder a las reglas de la sana crítica, según lo establece el Artículo 141 ibídem.

De igual manera, deben reunirse de manera conjunta los requisitos de legalidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, reglados en los artículos 4, 5 y 13 de la Ley 734 de 2002, los cuales es menester se encuentren debidamente acreditados dentro del sumario a partir de elementos de prueba legalmente allegados al proceso, como se procede a esbozar según arrojan las pruebas allegadas en la totalidad del proceso.

6.2 DEL CASO EN CONCRETO

En este acápite se relacionarán los medios probatorios, documentales y testimoniales, recaudados en estricto cumplimiento al artículo 129 el cual establece la imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba, imponiéndole, en tal sentido, el deber de investigar con igual rigor los hechos que demuestren la falta disciplinaria y los que la descarten. para así finalmente valorarlas acudiendo a la lógica y la sana crítica:

Prueba documentales

1. - Copia del correo electrónico de XXXXX, de fecha martes 02 de diciembre de 2014, dirigido a XXXXX, con copia a XXXXX, XXXXX, XXXXX, sobre la Solicitud de Guía Servientrega, del acto administrativo 10067 del 6 de octubre de 2014.

Se consigna allí:

**"Solicito de manera atenta su colaboración, en virtud de que con la planilla de remisión No. 602 del Despacho la cual remito enviar adjunta, se envió el 7 de octubre de 2014 a notificar a dos direcciones el acto administrativo 10067 del 06 de octubre de 2014, el cual no cuenta aún con No. de guías ni en las bases de Servientrega ni en el aplicativo notificar.**



POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

***Solicito entonces de manera urgente las guías correspondientes al acto administrativo, toda vez que somos requeridos por un derecho de petición por parte del contribuyente el cual vence el día de hoy (sic) <sup>5</sup>. (Negrillas propias)***

2. - Copia de la planilla de remisión 602 de fecha 07-oct-14, mediante el cual se observa el acto administrativo con el consecutivo 10067, NIT 860524654 de la Aseguradora Solidaria de Colombia, entidad Cooperativa y a la Agencia de Aduanas Move Cargo, con 14 folios. En el cuadro de entrega aparece que no existe. Funcionario que recibe XXXXX, fecha 7-10-2014 y funcionario que entrega XXXXX.

3- Oficio de fecha 30 de diciembre de 2014 dirigido al Jefe de Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registros de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, suscrito por la Dra. XXXXX, mediante el cual informa que al consultar el aplicativo.

NOTIFICAR, se evidencia la trazabilidad del procedimiento realizado para la entrega del citado acto'N administrativo a ese Despacho, así como la planilla No 602 de la Coordinación de Gestión de Recursos Físicos, la cual fue recibida por el funcionario XXXXX, en físico, para realizar la entrega a la empresa SERVIENTREGA y así iniciar el procedimiento para la notificación por mensajería expresa.

Al revisar el pantallazo del aplicativo Notificar, sobre el histórico de trámite de actos/oficios de fecha 6 de diciembre de 2014, en el proceso de notificación, no figura que el trámite hubiese pasado de la funcionaria XXXXX.

4. -Información de Historias Laborales sobre los disciplinados:5

XXXXX. Ingres a la entidad desde el 4 de julio de 2014 en planta de empleos temporales, desempeña el cargo de Analista II Código 02 grado 2, en Coordinación de Notificaciones-Subdirección de Recursos Físicos, Nivel Central. Dirección de residencia Avenida Ferrocarril No. 103 a 35 Bogotá.<sup>8</sup>

XXXXX, vinculado en planta de empleos temporales desde el 02 de enero de 2012, desempeña el cargo de Analista III Código 203 grado 3 en la Coordinación de Comunicaciones Oficiales Control de Registros. Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, Nivel Central. Dirección de residencia, Carrera 76 C 64-10 Centro la Candelaria Bogotá.

5. - Copia del correo electrónico de fecha 02 de diciembre de 2014 .04:58 p.m, enviado a XXXXX, por el funcionario XXXXX. Deja allí constancia Carlos Molina de lo ocurrido con la planilla No. 602 de la Coordinación de Recursos Jurídicos, aceptando que fue recibida por él, en físico, aseverando que como no estaba generada en la planilla de correspondencia, tal vez por no haber sido recibida por la Coordinación de Notificaciones, fué la razón por lo cual no le fue posible generar las planillas de correspondencia y así enviar los actos administrativos o citaciones.

6. Copia del correo electrónico de fecha 3 de diciembre de 2014, emitido por XXXXX, Jefe de Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registros, Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, con destino a XXXXX de las Coordinación de Notificaciones, con copia a XXXXX, XXXXX y XXXXX, señalando:

***"Realizadas las averiguaciones sobre la situación presentada con el acto administrativo 10067del 6 de octubre de 2014, me permito informar que ésta coordinación considera ocurrió con dicho acto: La planilla de remisión No. 602 de la Coordinación de Gestión de Recursos Jurídicos fue recibida por el funcionario Carlos Molina en físico, pero no se le generó la planilla de correspondencia por cuanto esta no fue recibida en el aplicativo por la Coordinación de Notificaciones. De acuerdo a los procedimientos actuales no es posible que la Coordinación de comunicaciones Oficiales y Control de Registro genere las planillas de correspondencia y envíe los actos administrativos o citaciones sin este paso, además si la Coordinación de Notificaciones hubiera recibido la planilla 602y nosotros hubiéramos generado la planilla de correspondencia, estos actos o citaciones estarían aun presentes en el sistema notificar para generarla respectiva planilla de correspondencia, lo cual no se observa ya que no se evidencia que esté presente en el mismo sistema.***

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

*Por lo anterior no es posible que el funcionario Molina haya devuelto la planilla 602 con los documentos soportes a la Coordinación de notificaciones (sin evidenciar alguna firma), para que fuera recibida por ellos y que por la cantidad de documentos que se manejan en el sistema notificar ya que son varias las dependencias que remiten planillas a esta dependencia, haya olvidado reclamarlas y poder generarle la respectiva planilla de correspondencia. Por tal razón, a partir de la fecha, las planillas que sean traídas por el funcionario de la Coordinación de Notificaciones, no serán firmadas por el funcionario encargado hasta tanto no se puedan generar e imprimir las respectivas planillas de correspondencia ya que en repetidas oportunidades envían 2 o 3 actos o citaciones y en el sistema figuran más de 5, para lo cual no es posible pasar a radicar parcialmente la planilla por falta de algunos", (negrillas y resaltado por el Despacho).*

7. - Histórico de Trámites actos/oficios de la XXXXX, de fecha 6 de febrero de 2015<sup>10</sup>. Hora 17:22, página de 1 -2. Allí se tiene la descripción del acto No. 601 el cual tiene la resolución que resuelve recurso de reconsideración, capturado el 6 de octubre de 2014 por la funcionaria XXXXX, el mismo 6 de octubre por la funcionaria XXXXX, quien anota que la naturaleza del acto es la notificación por correo y no personal como aparece en el aplicativo. Lo anterior constituye un claro ejemplo de corrección registrado en el aplicativo-

Continuando, se tiene que el día 7 de octubre, la funcionaria XXXXX pasa asignado a XXXXX, transcurriendo más de tres meses para pasar al funcionario XXXXX, esto es, tan solo el 22 de enero de 2015, con la nota de cambio de los tipos de correo y entrega, y luego con estado de planilla de correspondencia de fecha 22 de enero de 2015, pasa a XXXXX.

8. Acto Administrativo de la Subdirección de Gestión de Recursos jurídicos. El acto es identificado con el número 601, resolución que resuelve recurso de reconsideración, consecutivo No. 10067 del año 2014, de fecha 6 de octubre de 2014. Notificación por correo, con planilla de remisión 602 el 7 de octubre de 2014, posterior a ella hay otra planilla de correo, la 167 de fecha 22 de enero de 2014, planilla de devolución 6 de octubre de 2014 y fecha de ejecutoria 4 de diciembre de 2014.

9. Planilla de Devolución de Actos al Área Técnica, número 40. Seccional 223 Recursos Jurídicos, de fecha 6 de febrero de 2015, hora 04:51 p.m, de la dependencia de Coordinación de Secretaría de Recursos Jurídicos, acto número 647, resolución de recursos de reconsideración, Sanciones Independientes (Que confirma). El Motivo de Devolución es que no llegó el Auto, de fecha 5 de febrero de 2015. Resolución por bloque, escrito a mano alzada.

10. Visita Administrativa a la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos con el objeto de allegar la resolución No. 900.052 del 3 de febrero de 2015, la cual resolvió el silencio administrativo positivo que da cuenta la presente investigación^, decisión en la cual queda expuestos con claridad los argumentos jurídicos que dan sustento a la declaratoria del silencio administrativa positivo, ocasionando por la mora en el acto de notificación. Se consiga en el citado acto administrativo:

**“Consta en el expediente los siguientes hechos: Obra en el expediente, la resolución No. 103-241- 201-644-0-0648 del 25 de junio de 2014, por la cual la División de Gestión de Liquidación de la Dirección seccional de Aduanas de Bogotá, sancionó a la Sociedad AGENCIA DE ADUANAS MOVE CARGO S.A ..., con la multa de QUINIESTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/cote (\$505'832.857) equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la mercancía decomisada con actos administrativos... Contra estos actos administrativos los representantes legales de la AGENCIA DE ADUANAS MOVE CARGO S.A NIVEL 1 y de la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, interpusieron los recursos de reconsideración radicados No. 615 del 25 de julio de 2014 y 619 del 25 de julio de 2014,.. Como quiera que los recursos de reconsideración interpuestos contra la Resolución No. 1-03234- 201-644-0-0648 del 25 de julio de 2015, fueron radicados ante la autoridad aduanera el 23 y 24 de julio del 2014, según lo preceptuado en el artículo 515 del Decreto 2865 de 1999, modificado por el Decreto 3329 de 2009 en cita, el término de tres (3) meses para notificarla decisión, vencía el 24 de octubre de 2014.**

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

*La Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, como dependencia competente, mediante Resolución No. 10067 del 6 de octubre de 2014, resolvió los recursos de reconsideración presentados contra la Resolución No. 1-03-241-201-644-0-0648 del 25 de junio de 2014. Dentro del término de tres (3) meses, establecido en el artículo 515 del Decreto 2856 de 199. (Folios 1.436 a 1.450 vuelto).*

*El mismo día, 6 de octubre de 2014, (dieciocho (18) días antes de que se venciera el término de los tres meses establecido en los artículos 515 y 519 del Decreto 2685 de 1999, para notificar la decisión del recursos) el GIT Secretaría de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos con Planilla No. 598, radicado de correspondencia No. 002734, remitió el acto administrativo al GIT Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la DIAN, para que efectuara la notificación por correo de acuerdo con la competencia y procedimientos administrativos establecidos para el efecto, (folio 1.453)*

*Con Planilla No. 211 del 6 de octubre de 2014, el GIT Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, devolvió el acto a notificar al GIT Secretaría de Gestión de Recursos Jurídicos, con la anotación: "La naturaleza de la notificación es por correo y no personal como aparece en el aplicativo" sin ninguna otra explicación. (Folio 1.453 vuelto).*

*La Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, mediante Planilla de Remisión No. 602 del 6 de octubre, (diecisiete (17) días antes de que se venciera el término) devolvió el acto nuevamente al GIT Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, para que surtiera la notificación por correo en aplicación del artículo 567 del Decreto 2685 de 1999 (Folio 1.454)*

*Mediante correo electrónico de 2 de diciembre de 2014, la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la DIAN, solicitó instrucciones al GIT Secretaría de la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos respecto de la Resolución No. 10067 del 6 de octubre de 2014, informando que "partiendo del punto que es una resolución aduanera donde se tiene 3 meses para demandar y este término vencía el 24 de octubre del 2014, y que no se notificó, opera el silencio administrativo positivo." (Folio 1.455 (Subraya el despacho)*

*El 2 de diciembre de 2014, la Coordinación de Secretaría de la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos manifestó al GIT de la DIAN, que "La Resolución 10076 del 6/10/2014, AGENCIA DE ADUANAS MOVE EXPEDIENTE IS1114977, INTERPUSO Recurso el 13/07/2014. Lo que indica que el 23/10/2014 la Resolución tenía que estar NOTIFICADA... La Resolución, se envió con suficientes días para que se surtiera en debida forma la NOTIFICACION POR CORREO según el artículo 567 del Decreto 2685 de 1999". (Folio 1.456) (Subraya el Despacho)*

*A folio 1450 vuelto, obra constancia de la Coordinación de Notificaciones del Nivel Central donde certifica que el acto administrativo fue notificado por correo el 03 de diciembre de 2014, mediante las guías Número 1300001660169 y 130001660170, quedando ejecutoriada el 04 de diciembre de 2014, esto es, cuarenta y un días después de vencido el término para resolver y notificar la decisión del recurso. Dado que el primer recurso de reconsideración fue interpuesto el 23 de julio de 2014, el término de tres (3) meses para notificar la decisión vencía el 23 de octubre de 2014; como la Resolución No. 10067 del 6 de octubre de 2014 que resolvió los recursos de reconsideración fue notificada el 3 de diciembre de 2014, resulta evidente que la notificación es extemporánea, independiente de las responsabilidades de los funcionarios, que por razones a establecer, no notificaron dentro del término legal la Resolución No. 10067 del 6 de octubre de 2014, es evidente que frente a la misma operó el Silencio Administrativo Positivo, en tanto que una vez transcurrido el plazo para su oportuna notificación, la misma no se surtió dentro de los preceptos legales dispuestos en los artículos 515 y 519 del Decreto 2685 de 1999 en cita".*

11. Oficio de la Coordinación de Secretaría de Recursos Jurídicos XXXXX, dirigido a la Jefe de División de Gestión Jurídica de la Seccional de Aduanas Bogotá, mediante el cual remite varios expedientes, entre ellos el objeto del silencio administrativo positivo que refiere esta investigación, dejando establecido que el expediente IS 2011 2014 977 de la XXXXX, falló recurso de reconsideración No. 10067 el 6 de octubre de 2014.

12- Acta de visita administrativa realizada en la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos,

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

Coordinación de Notificaciones Sendas, cuya finalidad es verificar la trazabilidad en el proceso del aplicativo Notificar, del acto administrativo No. 1-03-241-201-644-0-0648 del 25 de junio de 2014, emitido por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección seccional de Aduanas de Bogotá, mediante la cual se sancionó a la Sociedad AGENCIA DE ADUANAS MOVE CARGO S.A, con multa de QUINIESTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/cote (\$505'832.857)

Allí se informó que la pantalla captura la planilla de remisión del acto administrativo la cual se remite al área de Notificaciones con los actos en físico relacionados en ella, también la planilla llega virtualmente. El notificador al momento de recibir la planilla la verifica físicamente con la planilla virtual y los actos relacionados en ella.

Agregó el funcionario que, para la fecha de los hechos se enumeraban los actos por parte del área misional, que en este caso sería la oficina de origen del acto, por razón de un plan de contingencia, para generar la agilidad del proceso.

Al respecto indicó el ingeniero XXXXX, quien atendió la diligencia:

***"...al recibir los actos administrativos contenidos en la planilla, en el aplicativo notificar por parte de la Coordinación de notificaciones, el acto se hace visible para continuar el proceso de correspondencia en el aplicativo, en manos del funcionario asignado en la Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registros, el cual se encarga de verificar los actos recibidos y entregarle la correspondencia a la empresa de mensajería".*** (negrillas del Despacho)

Se prosigue la visita administrativa en las oficinas de la Coordinación de Notificaciones y de Mesa de Ayuda, a efectos de conocer el proceso que se surte en el aplicativo NOTIFICAR, para tal efecto se ingresa específicamente al acto administrativo investigado, identificado con el número 10097, observándose que la planilla de remisión no tiene relacionado el tipo de envío, sin dejar comprobar más información.

En la anterior diligencia expuso la funcionaria XXXXX, Jefe de la Coordinación de Comunicaciones y Control de Registros de la DIAN, que al recibir los actos administrativos contenidos en la planilla en el aplicativo notificar por parte de la Coordinación de Notificaciones, el acto se hace visible en el aplicativo para así continuar con el proceso de correspondencia, en manos del funcionario asignado en la Coordinación de Comunicaciones Oficiales y así entregar la correspondencia a la empresa de mensajería.

13.- Inspección Administrativa realizada a la Subdirección de Gestión Tecnológica de Información y Telecomunicaciones de la DIAN, diligencia atendida por el ingeniero XXXXX, cuya finalidad fue conocer la trazabilidad de la notificación del acto administrativo número 10067 del 6 de octubre de 2014, dentro del aplicativo notificar, en su recorrido de la Coordinación de Comunicaciones hacia la Coordinación de Notificaciones.

Se informó por quien atiende la diligencia que, para la fecha del mes de octubre del año 2014, a la actualidad se han realizado ajustes al sistema para corregir inconsistencias que se presentaban al momento de devolver el acto, como prueba de ella se tiene las solicitudes de la mesa de ayuda para corregir inconsistencias como la de obligar a diligencias de tipo de impuestos y el tipo de entrega, lo cual se enmendó recientemente.

Luego de la anterior introducción explicó sobre la trazabilidad del acto administrativo que, al revisar en el sistema el aplicativo Notificar sobre el proceso surtido al acto administrativo identificado con el número 10067, presenta la siguiente trazabilidad:

***"Se recibe el acto jurídico mediante la planilla No. 598 con tipo de notificación personal, recibido por la funcionaria NATALY MIRANDA el 6 de octubre de 2014, quien observa que el tipo de notificación no corresponde con la naturaleza del acto, ese mismo día 6 de octubre se devuelve por la misma funcionaria al área misional, regresando el 7 de octubre de 2014, una vez verificado los requisitos se***



POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

***procedió a enviar al área de comunicaciones oficiales con la planilla No. 602."***

En la continuidad del acto, en el aplicativo se observa el pantallazo 1, el nombre de la razón social XXXXX, código del acto 601, consecutivo del acto 10067, con código de notificación CO, fecha del acto 6 de octubre de 2014, sin observarse la fecha de remisión de la planilla, ni fecha de planilla correo, de igual forma se observa el mismo pantallazo para la Aseguradora Solidaria de Colombia, con la misma información anterior, sin más datos.

El pantallazo registrado en la imagen 2 corresponde al paso que genera la planilla con la que se remite el acto administrativo del área Técnica de la Subdirección Jurídica con destino a la Coordinación de Notificaciones, con el acto consecutivo 601 y los Nit del contribuyente y aseguradora a notificar, fecha del acto octubre 6 de 2014 y fecha de cambio de estado 28-06-2015 a las 10:32.

El pantallazo número 8 del aplicativo notificar sobre GENERAR PLANILLA CORREO, deja ver que se encuentra en "Admón. 223, Depe. 201 Despacho, Entrega 1. Local urbano", sin más datos, registro que según el ingeniero afirmó que, si no se diligencia el código de entrega no permite realizar la planilla de correspondencia, afirmando, además:

***"si la persona que va a generar la planilla de correspondencia no puede ver el acto por el sistema, debería devolverlo con quien recibió el acto o en su defecto remitirse a la mesa de ayuda para que verifique el motivo por el cual no se ve en el sistema para generarla planilla.***

***"cuando el acto ya se encuentra en el proceso de planilla de correspondencia, quien tenga el rol de recibir el acto puede realizar la modificación del código de entrega, quien en este caso es la Coordinación de Notificaciones tal como aparece en el pantallazo 9y 10" Pantallazo que muestra que el Sistema Notificar tiene en el indicador Recibir la posibilidad de modificar tipo de Correo, recibir acto, generar planilla Devolución Área Técnica e Imprimir Planilla evolución".***

14.- Oficio respuesta del registro del acto administrativo No. 10067 del 6 de octubre de 2014 en el aplicativo Notificar, por parte de la Subdirección de recursos Físicos, por XXXXX, funcionario de la Coordinación de Notificaciones. <sup>16</sup> Se anexa el pantallazo sobre el código del caso No. 176453, autor ANA SOFIA MARTINEZ, estado cerrado, fecha del acto 06-10-2014, planilla en Excel de control de procesos, observándose el histórico para la persona jurídica Move Carga, nivel 1 y la Aseguradora Solidaria de Colombia, con fecha de ejecutoria el 4 de diciembre de 2014, fecha de notificación el 3 de diciembre de 2014, identificación de planilla 3373, código de administración 223.

Así mismo, se allega copia del Histórico de trámite de actos /oficios, de fecha 19 de agosto de 2015, del Despacho de la oficina de Recursos Jurídicos.

Sobre la resolución que resolvió el recurso de Reconsideración 10067 del 6 de octubre de 2014 se tiene: el código del acto 601, que hace alusión al tipo de decisión, NIT, razón social, esto es, los destinatarios del acto administrativo, Move Cargo y Aseguradora Solidaria, tipo de notificación, la cual aparece para el día 6 de octubre de 2014, PERSONAL, posterior a ello aparece Notificación por CORREO, con fecha de modificación el 7 de octubre de 2014, una vez la anterior corrección aparece como Responsable XXXXX y el 22 de enero de 2015, asignado a XXXXX, con observación: CAMBIO LOS TIPOS DE CORREO Y ENTREGA.

Luego se tiene planilla de Correspondencia el 22 de enero de 2015 XXXXX, misma fecha anterior en que aparece notificado y ejecutoriado el acto administrativo, a cargo de la misma funcionaria.

15. Manual de funciones de XXXXX, XXXXX y XXXXX, para el periodo de los hechos investigados. Se informa por la Subdirección de Gestión de Personal respecto de los manuales de funciones en el periodo del año 2014, la siguiente información:

XXXXX, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.984.458, vinculada con la DIAN como supernumeraria, desde el 07 de octubre de 2014 hasta el 03 de julio del 2014.

**POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083**

Para el periodo del 14 de octubre de 2014 se desempeñaba en la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la Unidad Administrativa Especial DIAN, del 4 de julio de 2014 al 13 de octubre de 2014 en el Despacho de Subdirección de Gestión de Recursos Físicos; periodo anterior en el cual desempeñaba las siguientes actividades relacionadas con los hechos investigados:

- "Recibir, radicar y gestionar el trámite documental oportuno de entrada y salida de la correspondencia general y específica del área con base en las directrices y normas vigentes
- Registrar las actividades surtidas en el trámite de notificaciones y/o comunicaciones en los formatos establecidos, según los procedimientos vigentes y el aplicativo correspondiente de actos administrativos, con el fin de mantener actualizada la información
- Realizar dentro de los 5 días siguientes a la fecha del acto administrativo o a la fecha de su entrega por parte del área misional, los trámites necesarios para surtir las notificaciones y/o comunicaciones de actos administrativos, incluidas las subsidiarias, en forma manual o sistematizada.
- Verificar las notificaciones y ejecutoria de los actos requeridos y documentados bajo su responsabilidad e imponer los sellos correspondientes, atender los requerimientos de usuarios internos y externos, relacionados a los actos administrativos a su cargo.

CARLOS MAURICIO MOLINA GUTIERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.196.007 de Garzón Huila, con el rol comunicador, Operador III de los procesos misionales, estratégicos de control y de apoyo. (f. 256)

Como Analista III código 203 Grado 03 y ubicado en la Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control Registro de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la Unidad Administrativa Especial DIAN, registra la siguiente descripción de funciones y perfil del rol relacionada con los hechos investigados:

"1.- Recibir, radicar, organizar y verificar requisitos de los documentos inherentes a los procesos adelantados, con el fin de apoyar la ejecución de los mismos.

3. -Administrar, generar y/o actualizar documentos bases de datos, de acuerdo a instrucciones impartidas por le superior inmediato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades propias del proceso en el que se desempeña.

... 9.- Ejecutar las labores de recibo y entrega de correspondencias interna y externa para garantizar el flujo oportuno de la información.

.12. Responder por la gestión documental y actualización de los registros y demás documentos relaciona con el proceso que se desarrolla en la dependencia.

16. - Manual del Usuario Sistema Notificar de fecha 13 de abril de 2012 vigente para la fecha de los hechos, mediante el cual la DIAN optimiza el procedimiento de notificaciones y en el cual podrá realizar los trámites necesarios para surtir las notificaciones a través del Sistema Notificar, de acuerdo con la normatividad vigente para llevar en buen término el procedimiento de una debida notificación de los actos administrativos proferidos por la entidad.

En él observamos que el procedimiento para la correspondencia externa de actos administrativos a notificar, se inicia en el aplicativo una vez es remitido por el área misional que capturó el acto administrativo y/o oficio, llenando allí toda la información requerida, quien luego lo debe enviar el acto físicamente al área de Notificaciones con una Planilla de remisión, para lo cual se debe ir al menú Oficios/actos, Captura/Modificación Planilla Remisión y seleccionar la opción de: correspondencia, actos Administrativos u oficios y actos según corresponda.

Veamos ahora qué indica el Manual sobre las correcciones cuando se ha generado la planilla de remisión y por alguna circunstancia es necesario proceder a realizar correcciones, como ocurrió en el caso que nos ocupa. Señala el manual en el punto 16 sobre corrección de actos devueltos establece:

***"...se requiere que el área de documentación genere la respectiva planilla de devolución indicando el motivo por la cual se devuelve el acto y/o oficio al área misional, para lo cual el funcionario que realiza el proceso de captura debe ingresar por el menú Oficios/Actos <sup>A</sup> Captura/modificación <sup>A</sup> Corregir Actos***

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

*devueltos.*

***El Sistema Notificar solicita que se indique si el proceso de captura del acto administrativo se generó con la estructura actual o con la estructura anterior, y debe seleccionar según corresponda dando clic en el botón aceptar, una vez realice este paso aparece la pantalla titulada "Identificación Acto Administrativo", en la cual debe proceder a seleccionar el acto que es susceptible de corrección y de clic en el botón aceptar y modifique los campo que se requieren corregir y proceda nuevamente a generar planilla de remisión."***

Ahora bien, existe un rol de recibir el acto el cual se informa en el Manual, será utilizado por el área de Documentación, quien recibirá los actos administrativos físicamente que han sido capturados previamente por el área misional, y el procedimiento para su uso es el siguiente den el aplicativo:

***"21.- ROL RECIBIR: Seleccionado el rol RECIBIR ACTO, se debe ir al menú Oficios/Actos -> Recibir <sup>A</sup> RecibirActo, aparecerá una ventana titulada RECEPCIÓN Y REPARTO DE ACTOS A NOTIFICAR, en la cual se encontrarán cuatro (4) diferentes criterios de búsqueda a saber: Dependencia, Tipo Acto, Tipo Notificación y Consecutivo Acto. Después de aplicado cualquier criterio de búsqueda, para verificar la totalidad de la información del acto administrativo a revisar, se procede a dar clic en el botón Ver Detalles y aparecerá una ventana titulada Detalles Recibe Acto.***

***Estando en esta ventana, aparecerá la totalidad de la información para verificar en el momento de la revisión. Verificada la información se debe dar clic en el botón regresar para volver a la ventana Recepción y Reparto de Actos a Notificar y confirmar la recepción.***

***Ubicados en la ventana Recepción y Reparto de Actos a Notificar, el funcionario encargado de la revisión procederá a marcar con un visto las opciones:***

***OK: Si el acto administrativo va a ser recibido por el Grupo de Documentación, se marcará con un visto la casilla ubicada debajo de este campo.***

***Reparto: aquí se asigna el acto administrativo para realizar el proceso de notificación." (negrillas del Despacho)***

17. Verificación en la página web de la Procuraduría General de la Nación, sobre los antecedentes Disciplinarios de los funcionarios, sin que en su contra exista sanción disciplinaria en contra de los aquí disciplinados, a la fecha.

18. - Copia de la Resolución 125 de 2013 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales<sup>19</sup>, de fecha julio 5 de 2013, por medio de la cual se modifica y adiciona las Resoluciones 0011 y 0012 del de noviembre de 2008.

Para tal efecto se dispone organizar la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, eliminado la Coordinación de Documentación y creando la Coordinación de Notificaciones y la Coordinación de Comunicaciones Oficiales y control de Registros.

Se dispone allí en el artículo 2°. la Creación de la Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registro en la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica, para el cumplimiento de las siguientes funciones, entre ellas las que se destacan son alusivas a los hechos endilgados (negrillas del Despacho):

***"1. Recibir, radicar, seleccionar y enviar la correspondencia externa que se origina en las dependencias del Nivel Central..."***

Artículo 3°. Crear la Coordinación de Notificaciones en la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica, para el cumplimiento de las siguientes funciones:

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

***"1. Numerar, fechar, notificar, efectuar el reparto y archivar todos los actos administrativos proferidos por las distintas dependencias que conforman el Nivel Central...."***

2. Notificar en forma personal o subsidiaria, si es del caso, a los interesados o a sus apoderados las providencias y los actos administrativos que profieran en desarrollo del proceso de su interés, cuyo domicilio, lugar de residencia o dirección procesal se encuentre dentro de su jurisdicción, independientemente del lugar de ubicación del funcionario que profiera el acto o providencia.

***... 11. Administrar en lo de su competencia los sistemas informáticos que se dispongan para la notificación y en especial del Aplicativo Notificar".***

#### Pruebas Testimoniales

1. - XXXXX. En su condición de Jefe de la Coordinación de Notificaciones, sobre los hechos refirió que, efectivamente se generó un silencio administrativo positivo de un acto administrativo procedente de la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, por la no notificación del acto a tiempo; trazabilidad del acto que se visualizar en el aplicativo notificar. El jefe en ese momento era la Dra. XXXXX y la responsabilidad es de cada notificador.

Deja conocer que las funciones de la jefatura de la Coordinación de Notificaciones están contempladas en el procedimiento 159-PR-FI -00159 y el memorando 390 de 2013, funciones que además incluye la de hacer el seguimiento a la notificación y a la ejecutoria de los actos administrativos expedidos por el Nivel Central.

Afirma conocer a los aquí investigados ya que son compañeros de trabajo; a XXXXX la conoce hace 2 años y a XXXXX hace 14 años.

Sobre el procedimiento para la notificación de los actos administrativos del nivel Central, señaló:

***"... los actos administrativos llegan por el aplicativo notificar, donde hay que dar claridad a la captura del acto, en este caso al Subdirector de Recursos Jurídicos, ellos generan una planilla de remisión, la cual es entregada con el acto físico a la Coordinación de notificaciones al procedimiento de numeración, se verifica los requisitos mínimos del acto y que se trate del mismo contenido en la planilla, la custodia<sup>22</sup> del original y le entregan una copia junto con la planilla al notificador que le corresponde el acto administrativo, luego del procedimiento de numeración, se le entrega al notificador con la planilla de remisión, por auto control se diligencia una planilla manual por notificador donde se relaciona el acto que se le está entregando y el notificador firma el recibido del mismo, de ahí en adelante está el proceso a cargo del notificador, él lo recibe en el sistema y con la misma planilla del aplicativo notificar que entrego el área misional del acto, se entrega a la Coordinación de Comunicaciones Oficiales el acto administrativo para enviar a través de correo e iniciar el trámite de su notificación, quienes una vez la reciben debe diligenciar la planilla de correo por la Coordinación de Comunicaciones Oficiales a través del aplicativo notificar, que está en el sistema, una vez se envía el acto la oficina de correos informa el número de la guía asignado y la oficina de comunicaciones la ingresa al aplicativo notificar, cuando se le entrega la guía física la Coordinación de Notificaciones ingresa la fecha de notificaciones de acuerdo a la normatividad aplicable o el procedimiento subsidiario, según el caso. Esta actividad la hace la Coordinación de notificaciones.***

Agrega: ***"... una vez el notificador recibe el acto administrativo en el aplicativo notificar, cambia a su estado de asignado donde el área de Comunicaciones Oficiales podrá realizar la planilla de correo correspondencia, para su posterior envío a la empresa de correo correspondiente, es el estado asignado que le da ésta opción, si el acto no está para ese caso puntual, no está en estado asignado, siendo ese procedimiento a cargo del notificador, que para este caso fue la funcionaria Ana Paola."***

En diligencia de ampliación de su testimonio solicitado en la etapa probatoria del proceso verbal, reiteró el trámite del procedimiento que involucra a las Coordinaciones, esto es, inicia con la capturar el acto administrativo en el aplicativo Notificar y termina con la planilla de remisión para entrega física del mismo a la empresa de mensajería.



POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

Al respecto reitera que se debe validar que lo físico y virtual tenga la misma información; para ello en la época de los hechos se enumeraban los actos administrativos en físico, luego se envía la planilla de entrega del acto.

Explica, si no coincide los virtual con lo físico se debe hacer la devolución en el sistema y se devuelve con la observación para corregir y generar la planilla de devolución.

Informó sobre el acto administrativo investigado, que no recuerda que haya existido una devolución, agregando que es fácil identificar en el aplicativo si existió o no una evolución o no coincidencia entre lo físico y lo virtual.

Expuso que, cuando se pide un informe al respecto se debe hacer una verificación del trámite en físico versus la auditoria del sistema.

Esgrimió que todos los actos administrativos, desde el 7 de enero del 2014 se deben registrar en el aplicativo notificar, era un requisito para hacer un seguimiento de los actos administrativos en Jurídica, por lo que era obligación capturarlo.

Afirma que el despacho a cargo del grupo debe hacer el seguimiento de ese acto, tal como se ha dado a conocer con memorandos, eso se hace mensual o bimensual y lo son sobre el seguimiento de culminación y verificar que en el aplicativo notificar todo este culminado, por lo que todo lo surtido es responsabilidad de cada notificador. Eso se hace por control del proceso y garantizar la culminación del proceso.

Afirmó que no todo ese proceso depende del notificador hay otro tramite de la Coordinación de Comunicaciones, cada uno tiene un rol que completa el proceso, el rol del notificador no es general una planilla de correspondencia ni generar un número de guía.

Aduce que si por alguna razón el encargado de comunicaciones oficiales, tenían los soportes físicos, y se trata de un acto que hay que notificar de forma inmediata, y no estaba alimentada la información, ellos podían ingresar la información siempre y cuando tuvieran los físicos para darle cumplimiento al requerimiento de la oficina de recursos jurídicos para poder notificar el acto.

Respecto de lo contenido en la planilla y la palabra que figura allí, NO EXISTE, dice que es un tema técnico, que no sabe que es, y esa planilla es del área misional de la oficina de Recursos Jurídicos. Sobre la implementación del aplicativo notificar afirmó, ese aplicativo esta divulgado para el Nivel Nacional desde el año 2013, no obstante estar diseñado desde el año 2011, para la Seccionales. Responde que para la fecha de los hechos no se enteró que haya existido algún problema técnico en el aplicativo, pero de ello no está cien por ciento segura.

En junio del año 2013 se crearon dos Coordinaciones la de Notificaciones y la de Comunicaciones Oficiales. En ese procedimiento se tuvo en cuenta la misma planilla con la que se recibe el acto del área misional, la misma que se entrega a Coordinaciones Oficiales, se recibe y se da el trámite correspondiente, para generar la planilla de correspondencia y se inicie el proceso de notificación, planilla que se debe someter al manual del usuario, se recibe el acto en el aplicativo que previamente el notificador ha recibido e inmediatamente le llega a comunicaciones oficiales para generar la planilla de correspondencia, él no tiene necesidad de buscarlo ya aparece en el sistema, insiste que debe coincidir lo físico con lo virtual.

Añade que no hay excusa para no notificar el acto si no hay sistema, se debe salvar el acto, se debe mirar y subsanar.

Responde al interrogatorio de la defensa de Ana Cleves, que el notificador tiene la tranquilidad que ya culmina su proceso cuando entrega el acto físico, pero el número de actos de notificación es tan grande, aun así, el acto administrativo tiene 5 días para notificar y para éste caso ya queda tranquilo, y para ello previamente se debe llegar al sistema para validarse; pero el proceso de notificación

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

realmente es cuando lo recibe el contribuyente.

Respecto a lo sucedido el 7 de octubre del 2014 y sobre las inconsistencias referidas por el Ingeniero Manjarrez y el procedimiento a cargo de la oficina de Comunicaciones, informó que solo responde lo que corresponde a Notificaciones Oficiales y el asunto es eminentemente técnico.

El aplicativo notificar en todo el tiempo que lleva, 15 años, siempre se le hacen ajustes, más allá de inconvenientes, son ajustes para mejorar la calidad de la notificación; los inconvenientes a que se refiere el ingeniero son ajustes para las interfaces y ese no es el caso que nos ocupa, pero no podría saber a qué se refiere el ingeniero XXXXX, a pesar de conocer bien el aplicativo notificar.

Respondió que no se dio ningún informe de parte del despacho de la Oficina de Notificaciones y no tiene conocimiento en esa fecha si habían fallas en el sistema, además que no recibieron ningún correo que informara que no se pudo iniciar el trámite y además el acto debió estar en el sistema de lo contrario no se había podido enviar la planilla de remisión y no sabe a qué se refiere la palabra NO EXISTE por cuanto eso es un tema muy técnico lo que ha sucedido en el sistema, ha podido ser que no se pudo ver, o no sabe cuál fue la razón.

Hay varios filtros para verificar errores, si es de fondo, en el de notificaciones, es allí, si es en de Comunicaciones igual lo debe hacer, el aplicativo permite devolver la planilla al área misional.

Responde que si en el aplicativo no se visualiza el acto para el área de comunicaciones informa que se debe tomar la captura del acto y enviar un correo para comunicar la novedad, y que hay errores que permiten hacer la devolución y otros que no, y en este caso no sabe cuál era el error.

Sobre el memorando citado por la Defensa, indicó que la implementación allí señalada del aplicativo notificar, estaba diferido al mes de septiembre de 2014, entendido a nivel nacional, para ello el plazo era hasta el 30 de septiembre; plazo que tenían la Seccionales para solicitar la codificación de los actos administrativos, a eso se refiere la fecha límite establecida en ese memorando.

Finalmente, afirma que cada área en su rol si tiene fallas lo puede registrar y devolver en el aplicativo y si el acto no es visible en el aplicativo para el área de comunicaciones oficiales, dependiendo del tipo de error, se sugiere tomar la captura de la pantalla y enviar un correo a la oficina de tecnología, pero hay otros errores que no permiten la devolución.

2. - XXXXX. Tecnólogo en Gestión documental del SENA, facilitador grado III en la DIAN Coordinación de Notificaciones, auxiliar administrativo, sus funciones son tramitar y custodiar la correspondencia de notificaciones, además le colabora a los compañeros como por ejemplo en la búsqueda de oficios, tramitar la correspondencia por medio de una planilla de notificar<sup>23</sup>, la cual lleva a la ventanilla de comunicaciones oficiales en forma física, allí le da el trámite el funcionario de comunicaciones que esté en el puesto.

3.

Sobre el caso investigado señaló que se enteró meses después, que el 6 de octubre se dirigió a comunicaciones oficiales, XXXXX le hizo el recibido de planilla, la cual archivo en el archivo de gestión.

Textualmente expuso: ***"Ha habido ocasiones en las cuales Carlos Molina genera la planilla de correspondencia en la que relaciona algunos autos que en ocasiones aún no están en físico, porque no lo hace el notificador encargado, él le da esa información verbal y se dirige a Coordinación de notificaciones solicitando esa planilla de correspondencia y los funcionarios le dan el trámite durante el día, eso ocurre con cierta regularidad, de cinco días en la semana acontece dos, eso creo debe ser por carga laboral."***

Así mismo informó que, recuerda que la planilla tiene el recibido con nombre y fecha del funcionario encargado del trámite, y además que en varias ocasiones se han presentado casos en que ha entregado la planilla de remisión en físico y al momento de verificar el aplicativo notificar éste no es visible para la Coordinación de notificaciones Oficiales, para lo cual ha debido dirigirse al funcionario

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

para que la corrija.

En diligencia de ampliación de su testimonio solicitado en la etapa probatoria del proceso verbal, señaló; las funciones que tenía para la fecha de los hechos era radicar la documentación de la Coordinaciones de Notificaciones, y su presencia en el proceso es porque hizo entrega del acto administrativo, paso por sus manos, refirió además que en notificaciones hace una planilla la cual hizo entrega a Carlos, no sabe qué problema tuvieron los compañeros en ese trámite. Afirma que en primera instancia se lo entregó XXXXX, luego se lo entrego a XXXXX quien se encarga darle el trámite, luego se desentiende del asunto.

Añade que, solo a mediados de diciembre se enteró del problema y le pide la planilla de remisión a XXXXX, donde constaba que le había entregado el acto, luego se enteró del silencio administrativo. Sabe que la planilla de remisión la genera Ana Paola luego cuando se entrega a XXXXX quien hace una planilla de correspondencia la que luego se le entrega y así archivarla.

Aduce que no tiene el rol del aplicativo notificar.

Explica que hubo varias ocasiones que XXXXX le pide que le diga al funcionario que reciba el acto, no sabe de qué se trata en específico, pero si puede decir que lo ha hecho en algunas oportunidades.

Afirma que no puede responder, cuántas veces en una semana se le ha requerido a Ana Paola sobre el registro del acto, pero si en ocasiones y dice que si presenta esos errores y el compañero Molina le dice que le diga a Ana Paola y ella lo arregla, allí en Notificaciones lo han embarrado muchos.

4. Declaración jurada de XXXXX. Para la fecha de los hechos era jefe la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Recursos Físicos de la XXXXX, hasta el 5 de julio de 2015 al ser nombrada Jefe de la Coordinación de Contratos.

5.

Sobre los hechos investigados informa que solo recuerda de un acto administrativo de la Subdirección de Recursos de la Dirección Jurídica que le fue asignado a XXXXX para el trámite de notificaciones, el cual debía surtirse a través de correo, hecho que puso en conocimiento a la Subdirección de Disciplinarios de la DIAN. A principios de diciembre del año 2014 se le puso en conocimiento por parte de la funcionaria XXXXX que el acto administrativo no había sido enviado nunca por mensajería expresa por parte de la Coordinación de Comunicaciones y Control de Registros, pese a haberse entregado de manera física a XXXXX.

Expuso que, en el aplicativo notificar estaba para el envío por correspondencia, que ella se había dado cuenta cuando la Subdirección de Recursos Jurídicos le había solicitado la prueba de la entrega y ella había acudido a dicha coordinación con el fin de que facilitara dicha entrega, encontrando con sorpresa la respuesta que el acto se le había sido devuelto a la Coordinación de Notificaciones por alguna falencia y no se había enviado a correspondencia, respondiendo que ella tenía la prueba de la entrega física del acto.

Deja saber que en su condición de jefe siempre se hacía seguimientos, se remitía a los notificadores la relación de actos asignados y pendientes de información de notificación en el aplicativo y se daban lineamientos respecto del trámite, como el estar pendiente de la entrega de los actos, de la devolución de las guías, de hacer requerimientos por escrito, con el fin de tener el control de los trámites asignados.

Sobre el trámite para el proceso de notificaciones de los actos administrativos señaló que, se debe realizar a través del aplicativo Notificar por el área dueña del acto, que para el caso lo fue la Subdirección de Recursos Jurídicos, captura la información en el aplicativo y lo deja en estado de envío al grupo de Comunicaciones y simultáneamente el área de origen entrega a notificaciones la planilla de entrega con el acto físico y con la misma planilla de remisión se entrega el acto físico a la Coordinación de Comunicaciones, el aplicativo deja ver el acto en el grupo de correspondencia, ellos solo lo saben hasta que lo reciben físicamente, debiendo hacer la verificación respectiva.

Agregó:

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

***"De haber alguna falla que le impidiera gestionar el acto, el proceder no era devolver a la mano el acto administrativo, es una mala práctica, sino hacerlo a través de correo electrónico o mediante un oficio a fin de dejarla evidencia.***

Afirma que los grupos sobre ese procedimiento gestionan un gran volumen de actos a diario, considerando que el hecho obedeció al desorden o se traspapeló por la cantidad que llega.

Recuerda que, de la Jurídica generan una cifra aproximada de 20 o 30 actos diarios para correo y de notificaciones personales otro tanto, además que se envían de otras áreas.

Además de lo anterior agregó que, para esa época se adelantaba un proceso de empalme con la nueva empresa de mensajería y había una mora en las pruebas de entrega de las guías, eso ocurrió a mediados de octubre del año 2014, había mucho lío y se debía dejar muchos espacios largos en espera de las guías por parte de esa empresa contratada.

Sobre el reparto de las tareas en el grupo por ella coordinado, señaló se hacían por áreas y en el caso de XXXXX, le correspondían las notificaciones por actos administrativos de la Subdirección de Recursos Jurídicos, cuyas notificaciones eran por correo, proceso que es el más fácil.

Es responsabilidad de cada notificador hacer la trazabilidad de los actos asignados. Antes de este hecho nunca se enteró de otros similares, pero luego de ellos Carlos Molina envió algunos correos sobre algún trámite pendiente, sin recordar que hayan sido con XXXXX.

Sobre el desempeño de XXXXX informó que es una funcionaria relativamente nueva, quien en unos inicios tenía confusión en el procedimiento, pero se dejaba guiar, ya que el trámite por ella adelantado es el más fácil, solo es revisar la planilla con la información del acto administrativo y enviar la planilla de remisión. La captura del acto administrativo lo hace el área de origen, ellos ingresan la información por el aplicativo y ya viene señalado como se va a remitir, con esa planilla física bajan los actos a notificaciones, ella tiene 5 días para remitir y como se deja ver ella lo envió el mismo día 7 de octubre de 2014.

En su ampliación de testimonio rendido en audiencia verbal, por solicitud de la defensa, reitera que para la fecha de los hechos era el jefe del Grupo de Notificaciones oficiales y recuerda el silencio administrativo por la no notificación de un acto administrativo.

Refiere que nunca manejó el aplicativo, pero entiende que el acto llega del área del origen a notificaciones, no sabe que hizo Ana Paola sobre la gestión del acto administrativo, entiende que la plantilla del oficio está en el aplicativo y junto con la planilla se generaba el oficio, pero eso depende del sistema de notificación.

Hace énfasis sobre la implementación de la resolución citada para el mes de septiembre del año 2014, era solo para el Nivel Nacional, donde debían acceder a un nuevo código de los actos administrativos dado que no estaban usando el aplicativo por no conocer el código del acto administrativo por lo tanto no tiene nada que ver con éste tema objeto del proceso., toda vez que el aplicativo viene funcionando desde hace muchos años.

La funcionaria a cargo del acto administrativo a notificar le indicó que entregó el acto administrativo y nunca se gestionó por comunicaciones oficiales, el aplicativo se debe gestionar y físicamente para enviar por correo.

No sabe cómo era la comunicación entre comunicaciones oficiales a notificaciones de errores, para la fecha de los hechos, la entrega a la mano no era la práctica.

Esgrimió que cuando ocurrieron los hechos, Ana Paola le informó que el acto nunca se notificó, sin recordar con exactitud, le dijeron que había algo malo; que se verificó que la planilla se recibió sin habersele hecho alguna devolución ni en físico ni en el aplicativo.



POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

En su condición de jefe de la oficina de Coordinación de Notificaciones Oficiales, siempre se les direcciona para que realizaran todo el procedimiento y mantener al día el aplicativo, aplicativo que nunca ha operado, pero entiende que se le deba dar algo o un chequeo para que el acto pase a comunicaciones oficiales, sin saber si lo hace jurídica u otro funcionario, pero sobre el acto administrativo tan solo se enterró cuando ocurrió el silencio administrativo.

3. - Declaración Jurada de XXXXX. Para la fecha de los hechos^ investigados no se encontraba de Coordinadora de Comunicaciones Oficiales, Control de Registros, como jefe asignada en reemplazo del titular, su llegada al grupo fue en la segunda quincena de diciembre del 2014.

Sobre los hechos refirió:

***"En la Coordinación de Notificaciones en el aplicativo Notificar envía virtualmente los actos administrativos susceptibles de notificar para que la Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registros, a través de la mensajería expresa Heve a cabo la citación o la notificación; de todas maneras para proceder en la Coordinación de Comunicaciones Oficiales se requiere la entrega por parte de notificaciones de los documentos físicos; esto quiere decir que sino se realiza la entrega virtual y la física, no se puede proceder a hacer el trámite respectivo de la entrega a la empresa de mensajería."***

Indicó que se enteró de oídas del asunto:

***"... y fue que no había coincidencia entre la entrega física y virtual, por lo tanto, el funcionario Carlos Molina hizo devolución del documento físico para que adecuara al procedimiento establecido, sin dejar ninguna constancia que demostrara la devolución'."***

Informó que estando como jefe de la Coordinación estuvo pendiente del desarrollo del proceso y al enterarse que el problema radicó que no hubo una forma de devolución, solicitó a los funcionarios de la Coordinación estar muy pendientes y no realizar ninguna entrega sin que medie una firma que así lo confirme.

Luego de este suceso, se enteró por lo menos de otro caso, igual al aquí investigado. En el mes de junio del año 2015 hubo una notificación que fue entregada a la Coordinación de Comunicaciones Oficiales en la ventanilla de Correspondencia interna, y no como debía hacerse en la ventanilla del Aplicativo Notificar, sin saber si eso haya causado algún perjuicio.

Sobre el desempeño de XXXXX expuso que es un funcionario que siempre da razón de su trabajo y realiza las actividades en oportunidad, su trabajo es trascendental y genera un estrés lógico, porque en momentos se congestiona el tema y tiene bastante carga.

Con respecto a la planilla No. 602 del 7 de octubre del 2014 que hizo entrega la Coordinación de Notificaciones a la Coordinación de Comunicaciones Oficiales y control de Registros, explicó:

***"... luego de ponerse de presente el acto administrativo, es un acto que debe notificarse a dos interesados, a la Agencia de Aduanas MOVE CARGOSA y a la Aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA, el cual se recibe por CARLOS el mismo 7 de octubre de manos de JHONATAN SAMUEL VELA. Pero si continuamos viendo el Histórico del trámite de actos oficiales a folio 5, como usted me lo deja ver, allí se aprecia que la Subdirección de Recursos Jurídicos, con fecha 7 de octubre del año 2014 hace entrega a la Coordinación de Notificaciones, concretamente a ANA PAOLA CLEVEZ, quien debía producir los oficios a la agencia y a la Aseguradora para notificar el acto administrativo, ella misma recibe por el aplicativo la planilla de la Subdirección de Recursos Jurídicos No. 602 a folio 4. Le corresponde igualmente a la funcionaria citada hacer entrega física y virtual del acto administrativa y de forma física del oficio y del acto administrativo para la Competencia de la Coordinación Comunicaciones que es la gestión del correo a través de la empresa de mensajería expresa."***

6.3 DE LA RESPUESTA A LOS ALEGATOS DE LA DEFENSA

6.3.1 Respecto de los argumentos de defensa del Dr. XXXXX.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

1. - Sobre sus argumentos referidos a los principios que deben regir el proceso disciplinario se debe recalcar que la actuación aquí nos ocupa, en todo momento se rigió por los principios que le regulan, consagrados en el libro I, título I, principios rectores de la ley disciplinaria, el de legalidad, bajo el entiendo que los funcionarios aquí investigados, han sido sometidos a ésta actuación administrativa sancionatoria, por comportamientos descritos como falta gravísimas al momento de la realización de la conducta, el principio del debido proceso, del cual diremos que ésta entidad es competente como se ha señalado en el inicio de estas consideraciones, por mandato legal.

4. En cuanto a su insistente planteamiento del cambio del procedimiento, de ordinario a verbal, lo cual sustento de la nulidad invocada de todas las probanzas allegadas, en dicha etapa, se debe reiterar lo esgrimido al momento en resolver la nulidad en oportunidad procesal, a saber, que si bien es cierto la actuación se inició bajo el procedimiento ordinaria y posteriormente se enmendó oportunamente dicho procedimiento a partir del acto de fecha 17 de junio del año 2016, mediante el cual se formuló pliego de cargos, retrotrayendo la actuación hasta antes del cierre de la investigación, ello lo fue a fin de no contravenir lo dispuesto en Título XI, Procedimientos Especiales, Capítulo 1, Procedimiento verbal:

"Artículo 175. Procedimiento verbal que se aplicará además para las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales, entre las cuales se incluye la falta aquí reprochada.

5. Sobre su análisis de la prueba testimonial, la defensa al valorar los testimonios de XXXXX y XXXXX, como medio probatorio indiscutible de la inocencia de su asistida, desconoce la integralidad de sus contenido y una conclusión en la que concuerdan, esto es, que el proceso se surte no solo con la entrega física del acto administrativo sino con el aplicativo notificar, en el cual se debe registrar el acto y continuar con el recibido para el decurso del proceso en el grupo de comunicaciones oficiales y así gestionar la respectiva planilla de correspondencia a la empresa de mensajería.

Efectivamente la prueba testimonial de oídas, como lo cita el tratadista Parra Quijano, corresponden a declarantes que no presenciaron de manera directa la comisión de los hechos, como en el caso de los aquí escuchados, y en particular los referidos por la Defensa para sustentar su petición de no imposición del fallo sancionatorio.

Esos testigos son XXXXX, jefe de la Coordinación de Notificaciones para le fecha de los hechos y XXXXX, compañera y posterior jefe del grupo, son consideradas de oídas por no haber percibido directamente los hechos, explicaciones que en su mayoría corresponden al relato de la disciplinada XXXXX, en apoyo al documento (planilla 602), para señalar que el proceso de parte de la Coordinación de Notificaciones se agotó y además que el posible error aludido por XXXXX, no le impedía cumplir el cometido de la comunicación oficial.

Estos testimonios como se ha reiterado, no solo doctrinalmente por el tratadista citado, sino jurisprudencialmente requieren de un ponderado análisis y una valoración crítica rigurosa y por lo tanto, no se les puede considerar determinantes en el sub lite, como si lo hace la defensa a criterio de su teoría del caso, por demás sesgada y parcializada como es lógico para los fines de su defensa.

En la realidad de la apreciación probatoria, debe ser sometida a las reglas de la sana crítica y la lógica, valoradas en su conjunto, siempre relacionado con los demás elementos probatorios que obren en el proceso.

La jurisprudencia al respecto señala:

***"No se puede desconocer que los testigos de oídas hacen parte de la prueba testimonial que, por regla general, es la prueba principal, de allí que, si bien su apreciación requiere un análisis riguroso y delicado, no se puede desconocer que es un instrumento valioso que se complementa apropiadamente con la prueba indiciaria o circunstancial. (...) este medio probatorio no debe ser entronizado por el juez, ya que si existen otros mediante los cuales se acredite la ocurrencia de unos mismos hechos, es evidente que ha de preferirse las pruebas originales, que hayan sido recaudadas de forma directa, cerca de la fuente. De allí que sólo será admisible su valoración en un escenario excepcional, en el que no se***

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

***adjuntaron otras pruebas que le permitan al juez tener conocimiento de la ocurrencia de los hechos, en cuanto a circunstancias de tiempo, modo y lugar, o simplemente si fue imposible recaudarlas, como en el presente caso. En efecto, resulta claro que el testimonio de oídas es una prueba que puede llegar a ser relevante en ausencia de otros medios. (...) " (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera. Consejero ponente: Enrique Gil Botero. 7 de julio de 2011, Radicación 20001-23-31-000-1999- 00136-01(21156)).***

En el caso sub examine, nos encontramos frente a una particularidad probatoria, ya que las testigos citadas conocieron de los hechos de manera indirecta, tiene una relación para con la disciplinada de forma directa entre jefe, subalterna y compañera, por manera que su dicho está revestido de cierta parcialidad en razón al sentido natural de apoyo y respaldo.

XXXXX, a contrario sensu de su inicial relato, esgrime que nunca ha manejado el aplicativo, lo cual resulta contradictorio y poco creíble por su naturaleza funcional, más aun, siendo un aplicativo con suficiente antigüedad para saber y conocer su manejo de su parte, por ello su relato se cuestiona, no resulta tan creíble y por demás se avizora parcializado dado el grado de compromiso que igualmente le deviene por haber sido jefe del grupo de Notificaciones Oficiales para la fecha de los hechos. (Indicio de mala justificación).

XXXXX, experta del aplicativo Notificar, sus explicaciones iniciales versus las de su ampliación de testimonio, resultan algo contradictorias, cuando inicialmente asevera que, si el encargado de Notificaciones no le da el estado asignado al procedimiento del acto administrativo en el aplicativo, esto es, lo recibe para dar su paso en el sistema al grupo de Comunicaciones Oficiales, no le permite visualizarlo y elaborar la planilla de Correspondencia para la empresa de mensajería (debe haber una concordancia entre lo físico y virtual, no solo en el contenido del acto sino en la trazabilidad del sistema, se conjugan las dos), en su posterior diligencia, aseveró bajo juramento que, Notificaciones culminó su proceso bastando solo para ello la planilla No. 602, teniendo como soporte de ello la prueba de recibido del acto administrativo.

Luego entonces, no se puede aseverar que hay culminación del proceso a cargo de Notificaciones oficiales, dado que no gestionó el proceso exigido en el aplicativo, divulgado en el manual diseñado y resoluciones, así como exigible en las funciones asignada a Cleves, por ende, la notificación se impidió en ese escenario (inferencia lógica).

Ora, el testimonio de XXXXX, ha sido consistente en su posición, no recordar la devolución de su parte del acto administrativo, o solicitud verbal de corrección para XXXXX, por solicitud de XXXXX, más sin embargo, reiteró en su ampliación que, este tipo de situaciones se viene presentando con cierta regularidad, luego entonces, lo aseverado por XXXXX queda en una realidad que se sustenta con éste testimonio y los correos electrónicos aportados que dejan conocer que la funcionaria Cleves comete errores de en el aplicativo notificar.

Ahora bien, el testimonio de XXXXX, jefe inmediato de XXXXX, no para la fecha de los hechos, expresa su conocimiento respecto del aplicativo notificar y la imposibilidad de emitir la planilla de correspondencia para la empresa de mensajería, cuando previamente no lo ha recibido el grupo de Notificaciones, esto es, concuerda con lo obtenido en la visita administrativa llevada a cabo en la Subdirección de Gestión de Tecnologías de la información y Telecomunicaciones de la XXXXX. Valga mencionar que, lo anterior no corresponde a apreciaciones subjetivas como insistentemente se refiere la defensa de XXXXX, ésta Subdirección Disciplinaria se basa en el análisis conjunto del material probatorio, bajo los postulados de la sana crítica y la lógica, lo cual exige precisamente definir qué elementos de juicio se les reconoce credibilidad y a cuáles no para llegar a su convencimiento sobre la verdad de lo acaecido, y así establecer la base fáctica de la presente decisión.

Igualmente, las testigos dejaron en claro que, el aplicativo Notificar lleva en funcionamiento muchos años y la Resolución No. 125 de 2013, no suspendía su aplicación al nivel central, sino a nivel nacional, mientras se les asignaban códigos a los actos allí tramitados, luego entonces, resulta errada la interpretación de la defensa, sobre que esa aplicación no debía tenerse como obligatoria

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

por estar suspendida para la fecha de los hechos.

6. La defensa asevera que, no existe prueba (ni documental ni testimonial) sobre devolución aludida por Carlos Molina a Ana Paola Cleves, a lo cual se debe señalar que su inferencia se desprende de la valoración probatoria del conjunto de las probanzas, a saber:

.- Las visitas administrativas dejaron establecido que XXXXX no registró en debida forma el proceso en el aplicativo

.- La prueba documental allegada por XXXXX sobre los oficios expedido por Ana Paola Cleves, de fecha 2 de diciembre del año 2014, con destino a los contribuyentes sancionados, por fuera del aplicativo Notificar y adjuntado copia del acto administrativo, indica que en sus manos reposaba el acto administrativo a notificar devuelto por Molina de manera informal.

.- Copia de correos institucionales enviados a XXXXX por XXXXX, ante situaciones similares y el testimonio de Jonathan Vela que igual deja saber que en la semana, por lo menos en dos ocasiones, se presentan ests incidentes.

7. - Veamos cómo, a pesar de la postura del doctor XXXXX, reconoce que XXXXX dejó conocer la obligatoriedad en las dos áreas (Notificaciones y Comunicaciones) de hacer el respectivo registro en el aplicativo, invitando a ver el procedimiento que fue regalado en la audiencia, el cual como ya se analizó deja más en claro ese proceso, dentro del reparto de tareas en los dos roles investigados.

8. - En cuanto a que la Defensa no comprende el principio de confianza aludido por la Defensa de Molina, nos remitimos al análisis que de ello se hace en las consideraciones de instancia, junto con la jurisprudencia que lo sustenta para los fines disciplinarios.

Por lo anterior, esta Subdirección Disciplinaria se aparta de sus postulados defensivos, por lo que, se puede afirmar, sí se demostró que XXXXX con su actuar dio lugar a la configuración de la falta disciplinaria descrita en el artículo 48, numeral 35, la cual establece como gravísima el "Dar lugar a la configuración del silencio administrativo positivo".

6.3.2 Alegaros de Defensa planteamientos de la Dra. XXXXX, defensora de Carlos Molina Gutiérrez:

.- Sobre sus postura referida a la inexistencia de ilicitud sustancial en el comportamiento de su asistido, le asiste razón a la profesional al afirma que XXXXX no pudo gestionar el acto de comunicación oficial como exige los procedimientos administrativos, ante el impedimento registrado en el aplicativo Notificar, generado por XXXXX, impidiéndole visualizarlo en el sistema, para así imprimir la planilla de envío a la empresa de mensajería, menos aún usar el aplicativo para realizar en el la corrección que se le presentaba.

Enfoque defensivo que, a la luz de la interpretación jurídica de la infracción disciplinaria, se ha enmarcado en sede de la atipicidad de la conducta, como más adelante se esbozará, acorde con el acertado principio jurisprudencia de la Confianza.

.- Respecto del verbo empleado en el auto de citación a audiencia verbal, lo inexcusable de la conducta desplegada por su asistido, en su momento se usó por razón de la imprudencia y negligencia al no haber insistido mediante los medios idóneos, correo electrónico u oficio, para el registro o código de entrega de parte de XXXXX, en el aplicativo notificar, aun así bajo este escenario procesal, lo inexcusable encuentra su explicación en lo que igualmente bajo la cita jurisprudencia que hizo la aquí defensora (Radicación 12655 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal el 30 de noviembre de 2006), la cual citó:

***"...en orden a examinarla violación del deber de cuidado objetivo, rige la regla de confianza, elaboración doctrinaria que parte del hecho de la intersubjetividad permanente del ser humano, razón por la cual, quien participa de una actividad riesgosa, compleja o delicada, en la medida que actúa diligente y cuidadosamente, tiene derecho a confiar en que los demás participantes harán lo propio." ...se insiste en que el principio de confianza no otorga derechos sobre los demás, simplemente obedece a una regla***



POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

***de la experiencia que razonablemente rige la interacción humana, motivo por el cual solo el cumplimiento del individuo en lo que le obliga y es su aporte al trabajo mancomunado, lo habilitara para confiar y no verse afectado por la malicia o despreocupación de los demás participantes."***

En este sentido, es comprensible que XXXXX, de acuerdo a la cotidianidad de su trabajo y la confianza que le dan sus compañeros, recibió la planilla sin verificar previamente su recibido en el aplicativo notificar, siendo esto una forma de dar cumplimiento de forma inicial a sus labores, que no se desconocen se vuelven dispendiosas por el volumen de actos que debe tramitar (ver testimonios recibidos), que si bien le fue imposible gestionar, acudió a lo que reiterativamente venía haciendo, solicitar verbalmente a XXXXX su registro en el aplicativo o recibido, siendo una regla de la experiencia que rige la interacción de los seres humanos que tiene a su cargo el reparto de tareas, lo habilitó para actuar y verse confiado, como efectivamente ocurría en casos anteriores, sin verse afectado por la malicia o despreocupación de sus otros compañeros a cargo del proceso, transcurriendo el tiempo sin que ese error fuese enmendado .

Son los anteriores argumentos que fundamentan la atipicidad de la conducta de XXXXXX, al no haber infringido con su comportamiento el artículo 48 numeral 35 del CUD, como más adelante se sustentará

#### 6.4. DE LA TIPICIDAD DISCIPLINARIA

##### 6.5.

De conformidad con el ordenamiento disciplinario vigente, son tres el tipo de faltas por las cuales eventualmente una persona puede ser llamada a responder disciplinariamente:

***"Artículo 42. Clasificación de las faltas. Las faltas disciplinarias son:***

- 1. Gravísimas***
- 2. Graves.***
- 3. Leves.***

Lo criterios para determinar la gravedad o levedad de las faltas están señalados en el artículo 43 de la ley 734 del 2002. Particularmente, la norma dispone dentro del catálogo de faltas gravísimas, la consignada en el artículo 48, así:

***"ARTÍCULO 48. Faltas Gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:***

***(...)***

***"35. Dar lugar a la configuración del silencio administrativo positivo."***

Acorde con lo dispuesto en el artículo 84 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solamente en los casos expresamente previstos en las disposiciones legales específicas, el silencio de la administración equivale a decisión positiva, entendiéndose que los términos para que se produzca la decisión positiva presunta comienzan a contarse a partir del día en que se presentó la petición o recurso.

El silencio administrativo objeto de la presente decisión, se estructura sobre la base de la Resolución No. 900.052 del 3 de febrero de 2015, bajo los siguientes planteamientos:

***"... La Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, como dependencia competente, mediante Resolución No. 10067 del 6 de octubre de 2014, resolvió los recursos de reconsideración presentados contra la Resolución No. 1-03-241-201-6440-0648, del 25 de junio de 2014. Dentro del término de tres (3) meses, establecido en el artículo 515 del Decreto 2856 de 199. (Folios 1.436a 1.450 vuelto).***

***El mismo día, 6 de octubre de 2014, (dieciocho (18) días antes de que se venciera el término de los tres meses establecido en los artículos 515 y 519 del Decreto 2685 de 1999, para notificar la decisión del recurso) el GIT Secretaría de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos con Planilla No. 598, radicado de correspondencia No. 002734, remitió el acto administrativo al GIT Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la DIAN, para que efectuara la notificación por correo de acuerdo con la competencia y procedimientos administrativos establecidos***

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

*para el efecto, (folio 1.453)*

**Con Planilla No. 211 del 6 de octubre de 2014, el GIT Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, devolvió el acto a notificar al GIT Secretaría de Gestión de Recursos Jurídicos, con la anotación: "La naturaleza de la notificación es por correo y no personal como aparece en el aplicativo" sin ninguna otra explicación. (Folio 1.453 vuelto). La Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, mediante Planilla de Remisión No. 602 del 7 de octubre, (diecisiete (17) días antes de que se venciera el término) devolvió el acto nuevamente al GIT Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, para que surtiera la notificación por correo en aplicación del artículo 567 del Decreto 2685 de 1999 (Folio 1.454)**

**Mediante correo electrónico de 2 de diciembre de 2014, la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la DIAN, solicitó instrucciones al GIT Secretaría de la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos respecto de la Resolución No. 10067 del 6 de octubre de 2014, informando que "partiendo del punto que es una resolución aduanera donde se tiene 3 meses para demandar y este término vencía el 24 de octubre del 2014, y que no se notificó, opera el silencio administrativo positivo." (Folio 1.455)**

Lo anterior permite inferir que existió una inobservancia expresa de las disposiciones contenidas en el artículo 515 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 50 del Decreto 1232 de 2001, cuando advierte:

**"Contra el acto administrativo que decida de fondo procede el recurso de Reconsideración. El cual deberá interponerse dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación. El término para resolver el Recurso de reconsideración será de tres (3) meses contados a partir de la fecha de su interposición..."**  
Por su parte el artículo 519 del mismo ordenamiento, modificado por el artículo 22 del Decreto 4421 del 2004: señala expresamente;

**"Los términos para decidir de fondo previstos en el presente Capítulo son perentorios y su incumplimiento dará lugar al silencio administrativo positivo..."**

**"... Igualmente, transcurrido el plazo para resolver el recurso de reconsideración sin que se haya notificado decisión expresa, se entenderá fallado a favor del recurrente en los términos previstos en los incisos anteriores, en cuyo caso la autoridad competente de oficio o a petición de parte así lo declarará".**

En el caso particular, el Despacho reitera que el recurso de reconsideración fue interpuesto contra la Resolución No. 1-03-241-201-644-0-0648 del 25 de junio de 2014, mediante la cual la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, sancionó a la Sociedad Agencia De Aduanas Move Cargo S.A, con multa de QUINIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/cote (\$505'832.857), recurso que fuere resuelto el 23 de julio de 2014, mediante Auto No 10067 de fecha del 6 de octubre de 2014, luego de lo cual la Administración contaba con el término de tres (3) meses para notificar la decisión, término que vencía el 23 de octubre de 2014; decisión que solo se notificó el 3 de diciembre de 2014, resultando así su extemporaneidad en la notificación dentro del término legal dispuesto en los artículos 515 y 519 del Decreto 2685 de 1999, lo que en consecuencia trajo consigo la materialización del silencio administrativo positivo a favor del recurrente, por un hecho atribuible a la Administración.

a. Adecuación típica del actuar de XXXXX:

La materialización del verbo rector exigido por el tipo disciplinario, vale decir, el "DAR LUGAR" al silencio administrativo, acontece sin duda alguna en el proceso de notificación, al comprobarse que el día 6 de octubre de 2014, el GIT de Secretaría de la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos con la planilla 598, radicado de correspondencia No. 002734, remitió el acto administrativo No. 10067 al GIT Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la XXXX, para que efectuara la notificación, la cual es devuelta y corregida el 7 de octubre de 2014, sin que luego de ello se tramitará en debida forma el acto de comunicación y notificación de

**POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083**

parte de XXXXX del GIT Coordinación de Notificaciones, por no haber cambiado el estado asignado del procedimiento en el aplicativo Notificar, no obstante haberse enviado de forma física junto con la planilla de remisión del acto administrativo a XXXXX del GIT de la Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registros, no le fue visible y por ende no podía proseguir con el proceso y así expedir la planilla de correspondencia para ante la empresa de mensajería si serle visible en el aplicativo, requiriendo a Ana Paola Cleves de forma verbal.

La adecuación de la conducta artículo 48 numeral 35, infringida por XXXXX, se sustenta probatoriamente con los siguientes elementos materiales:

S La planilla de remisión número 602 de fecha 7 de octubre de 2014, mediante la cual se hace entrega física del acto administrativo por parte de la Coordinación de Notificaciones a la Coordinación de Comunicaciones Oficiales, momento a partir del cual se inicia la mora en el proceso de notificaciones, toda vez que si bien es innegable el acto administrativo a notificar se entregó de firma física por XXXXX a XXXXX, esa sola entrega no permitió culminar el proceso de notificación, por no haberse hecho visible en el aplicativo notificar, con el cambio del estado asignado, proceso a cargo de XXXXX; el cual nunca generó.

S Los correos electrónicos surtidos entre los aquí disciplinados a sus jefes inmediatos, dejando en evidencia las circunstancias que rodearon la irregularidad, esto es la no culminación del proceso de notificación, a pesar de haberse hecho la entrega física del acto administrativo por parte de grupo de Notificaciones al Grupo de Comunicaciones Oficiales, de forma oportuna y el no registro del recibido del acto en el aplicativo notificar impidiendo la expedición de la planilla de correspondencia, por parte de éste último grupo.

S El histórico de actos administrativos y oficios de la XXXXX de fecha 6 de febrero de 2016, donde se observa que hasta el día 22 de enero de 2015 se emite la planilla de correspondencia del acto administrativo #900.052, de fecha 3 de febrero de 2015, el cual resuelve el Silencio Administrativo Positivo, esto es, no se tiene registro anterior de la notificación correcta del acto administrativo No. 10067 del GIT Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la XXXXX.

S Visitas administrativas llevadas a cabo en las Subdirección de Recursos Jurídicos de la Dian, Coordinaciones de Notificaciones y Coordinación de Comunicaciones Oficiales, así como en la Subdirección de Gestión de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de la XXXXX, lo cual mostró la trazabilidad del acto en el escenario de la Subdirección de Recursos Físicos de la DIAN (Coordinación de notificaciones y de Comunicaciones Oficiales, las cuales establecieron que el acto administrativo No. 10067 nunca cambio su estado de recibido de parte de XXXXX, dentro del aplicativo Notificar, para serle visible en el sistema a XXXXX y así generar en el sistema la planilla de correspondencia., tampoco allí se dejó establecido errores que hayan impedido tal proceso en el sistema.

Valga mencionar a este respecto que, no se puede aceptar como justificante el proceder de Ana Paola Cleves, según lo aseverado por la Defensa, al citar lo afirmado por el ingeniero a cargo de la Subdirección de Gestión Tecnológica de Información y Telecomunicaciones de la XXXXX, XXXXX, que para la fecha de los hechos, mes de octubre se venían presentado algunos ajustes al sistema, inconsistencias que se presentaban al momento de devolver el acto, falla que de haberse percibido se hubiese registrado en el aplicativo, menos aún, la mesa de ayuda que queda a pocos pasos de XXXXX, recibió información al respecto, como se constató en la visita administrativa allí adelantada. La trazabilidad del acto dejó conocer en el pantallazo número 8 del aplicativo notificar, que al generar la planilla de correo, no se observó el código de entrega de parte de XXXXX, lo cual impidió a XXXXX realizar la planilla de correspondencia a la empresa de mensajería para allegar el acto a notificar a los interesados, toda vez que se le imposibilitó apreciar el acto administrativo en el sistema para que pudiese bajar la planilla respectiva luego entonces se advierte de manera precisa que el paso previo, exigido en el aplicativo, no fue diligenciado por la disciplinada Paola Cleves, incurriendo en un proceder de evidente descuido e imprudencia de su parte.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

S De igual forma, los testimonios de oídas recepcionados, XXXXX, XXXXX, XXXXX y XXXXX, permiten concluir que el proceso exige no solo el envío en físico del acto administrativo por parte de la Coordinación de Notificaciones a la Coordinación de Comunicaciones Oficiales, sino debe ser alimentado en el sistema para su debida trazabilidad.

b. La adecuación típica de la conducta respecto de XXXXX.

El material probatorio recaudado deja colegir que la conducta de XXXXX, no logra infringir el artículo 48 numeral **"35. Dar lugar a la configuración del silencio administrativo positivo."** no se demostró que el funcionario XXXXX haya dado lugar a ello por haber transgrediendo los deberes funcionales encomendados en sus funciones, dado que su posición de garante en el proceso de Notificación del acto, no era de tal exclusividad, su proceso y gestión dependía del debido registro en el aplicativo notificar por parte de XXXXX.

Tanto así que, por razón de la relación laboral entre compañeros, informa el error a XXXXX, esto es, que debía recibir el acto administrativo en el aplicativo notificar, para el proceder de conformidad, es la confianza entre colegas lo que le permite hacerlo de manera informal, como se venía haciendo en eventos anteriores.

Ahora bien, respecto del rol y funciones a cargo de XXXXX, y atendiendo las labores en específico a él asignadas, dada su condición de analista III de la Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control Registro, con estudios de cuarto año de bachillerato y un año de experiencia al momento de comunicarle sus funciones, le correspondía, entre otras: **"Recibir, radicar, organizar y verificar requisitos de los documentos inherentes a los procesos adelantados, con el fin de apoyar la ejecución de los mismos"**.

Efectivamente, las probanzas dejan saber que éste servidor recibió la planilla de remisión del acto administrativo de forma física, para efectos de adelantar la correspondiente planilla de correspondencia a la empresa de mensajería, no así en el aplicativo Notificar.

Bajo esta ilustración y rol funcional asignado, se tiene que el señor XXXXX si cumplió con la función de:

**"Ejecutar las labores de recibo y entrega de correspondencias interna y externa para garantizar el flujo oportuno de la información"** lo cual se corrobora con su firma de recibido obrante en la planilla física No.602., recibió más no pudo enviarla a la empresa de mensajería por el obstáculo del sistema ya mencionado.

Ahora bien, el hecho de solicitar XXXXX, de forma verbal el debido registro del acto en el sistema por parte de XXXXX, sin dejar constancia escrita de ello, per se, no lo ubica en principio en acto omisivo o de un comportamiento ineficiente; pues como lo afirma la Defensa del funcionario, ello obedeció a un acto de confianza entre compañeros de trabajo, aunado a que no era la primera vez que ocurría tal evento.

Efectivamente tal como lo esgrimió la defensa de XXXXX, con la siguiente cita jurisprudencia, se ha de entender el principio de confianza:

**"Es cierto que una de las características del mundo contemporáneo es la complejidad de las relaciones sociales y, en materia de producción de bienes o servicios, la especialización en las diferentes tareas que componen el proceso de trabajo. Esta implica la división de funciones entre los miembros del equipo de trabajo y por lo tanto un actuar conjunto para el logro de las finalidades corporativas. Como no siempre es controlable todo el proceso por una sola persona y en consideración a que exigir a cada individuo que revise el trabajo ajeno haría ineficaz la división del trabajo, es claro que uno de los soportes de las actividades de equipo con especialización funcional es la confianza entre sus miembros. Esta, cuando ha precedido una adecuada selección del personal, impide que un defecto en el proceso de trabajo con implicaciones penales se le pueda atribuir a quien lo lidera, a condición naturalmente de que no lo haya provocado dolosamente o propiciado por ausencia o deficiencia de la**



POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

***vigilancia debida..." (Sentencia única instancia del 21 de marzo de 2002, M. P. Carlos Eduardo Mejía Escobar, radicación 14.124).***

Ahora bien, alrededor de éste principio, en materia disciplinaria como lo ha reiterado la Procuraduría General de la Nación, el principio de confianza opera si la circunstancia le permite al disciplinado razonablemente confiar que el otro compañero, en este caso, XXXXX, como había ocurrido en otros eventos, iba a corregir su actuar, más aún, cuando la misma conocía cuál era su misión y deber funcional y que su nivel de conocimientos en derecho, podía fácilmente inferir las consecuencias que ello acarrea.

La misma Procuraduría General de la Nación ha señalado sobre el principio de confianza, que es un elemento esencial dentro de las dinámicas para el reparto de trabajo y distribución de funciones, señalando al respecto:

"La Sala Disciplinaria reconoce la importancia del principio de confianza y su aplicación en materia de la función pública como elemento esencial para hacer posible el reparto de trabajo y la distribución de funciones que faciliten la realización de los cometidos estatales, pues de lo contrario se entraría la buena marcha de la administración pública al someter al funcionario a escudriñar cada una de las actuaciones y tareas realizadas por los demás sujetos intervinientes.

Sin embargo, la aplicación de este principio en el campo disciplinario tiene como condición: (i) que en el reparto de tareas, el ejercicio de las propias funciones asignadas al servidor público haya sido desarrollado con estricto apego a los principios de la función administrativa, esto es, con diligencia, eficacia, economía, celeridad, etc, y (ii) que exista fundamento normativo y fáctico que permita confiar válidamente en la tarea desplegada por los demás funcionarios con quienes interviene o comparte la ejecución de una labor o función determinada, pues la confianza debe aplicarse respecto de personas que tienen asignados determinados roles y competencias en el ámbito administrativo. (Decisión No. 161-4266 014-147753, de fecha Bogotá dos (2) de septiembre de dos mil diez (2010), aprobada en Acta de Sala No.37)".

Presupuestos que se evidencian en las funciones a cada uno asignadas, así como en el debido cumplimiento del Manual del Usuario Sistema Notificar de fecha 13 de abril de 2012, así como la Resolución 125 de 2013 que estableció unos correctivos en su implementación a nivel nacional, no loca; por ello no se puede manifestar que XXXXX haya desatendido sus funciones asignadas, cuando no quebranto el procedimiento allí exigido, por manera que no vulneró los principios que rigen la función pública., razones por las cuales se debe concluir que XXXXX no infringió el artículo 48 numeral 35 del CUD.

#### 6.5. DE LA ILICITUD SUSTANCIAL

El ejercicio de la función pública y la condición de servidor del Estado, exige un actuar ajustado a la Constitución y la Ley, lo cual implica acatamiento de deberes que trascienden el concepto de la función propiamente dicha, y llega hasta principios de naturaleza ética que deben animar el comportamiento público, que pasan por las nociones de probidad, transparencia y rectitud, entre otras, pero que dogmáticamente se conocen como "**deberes funcionales**", estrechamente atados a la calidad de servidor público.

En este sentido, la ilicitud sustancial hace alusión, a "**la oposición de la conducta desplegada por el agente frente a los deberes funcionales exigibles, concebidos estos como el pilar de la salvaguarda de la función pública, en cuanto atenta contra el buen funcionamiento del Estado y el cumplimiento de sus fines, (...)**"

Frente a este requisito ha señalado igualmente la Corte Constitucional en Sentencia C-77 de 2007 que:

***"(,)La Corte ha precisado igualmente que, en materia disciplinaria, la ley debe orientarse a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público o al particular que cumple funciones públicas pues las faltas le interesan al derecho disciplinario en cuanto interfieran tales***

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

***funciones (Ibídem). De allí que el derecho disciplinario valore la inobservancia de normas positivas en cuanto ella implique el quebrantamiento del deber funcional, esto es, el desconocimiento de la función social que le incumbe al servidor público o al particular que cumple funciones públicas (C-373 de 2002). (..) Asimismo cabe concluir que la infracción disciplinaria siempre supone la existencia de un deber cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento genera la respuesta represiva del estado(...) es necesario garantizar de manera efectiva la observancia juiciosa de los deberes del servicio asignados a los funcionarios del Estado mediante la sanción de cualquier omisión o extra/limitación en su cumplimiento, por lo que la negligencia, la imprudencia, la falta de cuidado y la impericia pueden ser sancionados en este campo en cuanto implique la vulneración de los deberes funcionales de quienes cumplen funciones públicas."***

Concomitante con lo expuesto, la Constitución Política de Colombia, Capítulo II, Artículos 122 al 131, la Ley 443 de 1998, la Ley 909 de 2004 y la Ley 4 de 1992, entre otras, establecen el marco regulatorio de la función pública. De igual manera, señalan sus rasgos característicos, que se pueden de la siguiente forma: la transparencia, eficacia, moralidad, mérito, igualdad, economía, imparcialidad, publicidad y celeridad.

De tal manera que, en el caso particular, los principios como el de celeridad y eficacia que rigen la actividad administrativa, se vieron socavados en el trámite del proceso de comunicaciones y notificaciones oficiales exigido a los funcionarios a cargo de dicho proceso, por razón de su rol, atribuyéndose dicha falencia como contraria a derecho y susceptible de reproche disciplinario.

a. De la Ilícitud sustancial desplegada por XXXXX

Para el caso en concreto, se observa la vulneración del principio de eficiencia por negligencia y descuido de parte de Ana Paola Cleves, quien para la fecha de los hechos venía cursando estudios de Derecho y quien, basado en las funciones a ella signado, se le impuso entre otros, la de:

***"Registrar las actividades surtidas en el trámite de notificaciones y/o comunicaciones en los formatos establecidos, según los procedimientos vigentes y el aplicativo correspondiente de actos administrativos, con el fin de mantener actualizada la información"***

Infiriéndose de lo anterior que, la servidora no gestionó en debida forma en el sistema o aplicativo notificar del acto administrativo citado, para así continuar con el procedimiento en la fase a cargo de XXXXX del grupo de Comunicaciones oficiales; esto, por cuanto al apreciar la trazabilidad del acto, se evidenció que la actuación siempre estuvo en su rol, inclusive desde que el área misional generó el acto y se lo remitió, tanto física como virtualmente; aun así, el acto administrativo nunca pasó en el aplicativo al Grupo de Comunicaciones Oficiales, labor que le correspondía gestionar.

Bajo esta óptica, XXXXX desconoció el deber implícito contenido en el numeral 35, artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que tipifica el comportamiento irregular que se le atribuye, al inobservar los principios de diligencia, celeridad y eficacia, ínsitos en la descripción, y que determina como contraria a derecho, como quiera que con su actuar, dio lugar a la configuración del silencio administrativo positivo, sin que se haya observado una circunstancia que justifique su actuar, pues en su condición de servidora pública debía actuar bajo postulados de moralidad pública, diligencia, eficiencia, eficacia y cuidado en sus actuaciones, es decir, a partir de normas rectoras de su ejercicio, tal como lo establece la ley disciplinaria en sus artículos 5 y 22, por cuanto al asumir su cargo la disciplinada, se comprometió a cumplir con fidelidad y respeto sus deberes funcionales legales y constitucionales; situación que considero el Despacho que en el sub examine no se cumplió, sino que por el contrario, la disciplinada afrentó sin justificación alguna los principios enunciados de la función pública a los que estaba obligada acatar y lo dispuesto en el artículo 732 del Estatuto Tributario - Decreto Extraordinario 624 de 1989.

Así las cosas, en orden a sustentar la afirmación del requisito de ilicitud sustancial de la conducta investigada, la misma se encuentra satisfecha frente al comportamiento desplegado por la señora XXXXX.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

## 6.6. DE LA CULPABILIDAD

Base fundamental del elemento subjetivo o de culpabilidad en el derecho disciplinario, es la proscripción de toda forma de responsabilidad objetiva. El cimiento de la misma lo constituyen las formas de culpabilidad establecidas por el ordenamiento disciplinario para el efecto, vale decir, el dolo y culpa.

Sobre el particular la Corte Constitucional ha señalado que:

*"Si la razón de ser de la falta disciplinaria es la infracción de unos deberes, para que se configure violación por su incumplimiento, el servidor público infractor sólo puede ser sancionado si ha procedido dolosa o culposamente, pues el principio de la culpabilidad tiene aplicación no sólo para las conductas de carácter delictivo sino también en las demás expresiones del derecho sancionatorio, entre ellas el derecho disciplinario de los servidores públicos, toda vez que "el derecho disciplinario es una modalidad de derecho sancionatorio, por lo cual los principios de derecho penal se aplican mutatis mutandi en este campo pues la particular consagración de garantías sustanciales y procesales a favor de la persona investigada se realiza en aras del respeto de los derechos fundamentales del individuo en comento, y para controlarla potestad sancionadora del Estado"*

Una particularidad que caracteriza al derecho disciplinario y que lo distingue de otros derechos represores, como el Penal, es la posibilidad de que el operador, respecto de una misma falta y con base en los fundamentos probatorios existentes, pueda otorgarle a aquella el carácter de dolo o de culpa, dependiendo de las condiciones particulares en que se fuera desarrollada la conducta investigada y de que la descripción del tipo disciplinario no contenga ingredientes normativos de carácter subjetivo que encuadren la conducta exclusivamente como dolosa. Este sistema denominado "numerus apertus" del derecho disciplinario lo distingue del "numerus clausus" del penal, en el que el legislador establece para cada conducta punible su forma de culpabilidad, particularmente cuando se trata de delitos que admiten la forma culposa.

En consecuencia, en el análisis del aspecto subjetivo, tratándose de la falta descrita en el numeral 35 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, es factible que la conducta de los investigados pueda enmarcarse dentro de cualquiera de las dos concepciones o formas de responsabilidad previstas en el derecho disciplinario, amén que bien pudo haber incurrido en forma dolosa o en forma culposa en la generación del silencio administrativo positivo.

De la situación jurídica de XXXXX

En cuanto a éste presupuesto, el acervo probatorio permite inferir que, Ana Paola Cleves Villarraga, es autora y responsable de la conducta descrita en el 35 del artículo 48 del CDU **"Dar lugar a la configuración del Silencio Administrativo Positivo"**, con ocasión de la no notificación en término, del recurso de reconsideración resuelto mediante resolución No. 10067 del 06 de octubre de 2014, según lo establece el artículo 515 del Decreto 2685.

Lo anterior por haber inobservando la aplicación de los términos allí exigidos, actuando con evidente descuido y violación del deber de cuidado que se exige de todo servidor público en el ejercicio de las funciones y atribuciones propias del cargo; funciones descritas en su manual, como son entre otras, el de registrar el acto administrativo en el aplicativo correspondiente y verificar la notificación y ejecutoria del acto, lo cual no realizó, por cuanto a pesar de haber enviado el acto físicamente al Grupo de Comunicaciones Oficiales, no gestionó el estado de recibir el acto, en el aplicativo Notificar, impidiendo así se hiciera visible el acto en el sistema por parte del XXXXX y efectuar la planilla de correspondencia para la empresa de mensajería.

Véase, además cómo una vez XXXXX se entera del vencimiento de los términos, expide los oficios de notificación exigidos, con fechas 2 de diciembre de 2014, sin numeración interna y enviados directamente por la ventanilla de correspondencia interna, obviando el trámite en el aplicativo Notificar., esto es por fuera de las exigencias normativas diseñadas por la entidad.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

Todo lo anterior se constata en el siguiente material probatorio:

a. - La prueba técnica arrojada en las visitas administrativas llevadas a cabo en las Subdirección de Recursos Jurídicos de la Dian, Coordinaciones de Notificaciones y Coordinación de Comunicaciones Oficiales, así como en la Subdirección de Gestión de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de la DIAN, al verificar el histórico del acto administrativo en el aplicativo Notifica, arrojando que el acto administrativo No. 10067 nunca cambio su estado de recibido en el rol de parte de XXXXX, funcionaria a cargo del Grupo de Notificaciones Oficiales, para serle visible en el programa a XXXXX y así generar en el sistema la planilla de correspondencia., tampoco se estableció allí errores que hayan impedido tal proceso.

b. - Los testimonios de personas conocedoras del sistema o aplicativo Notificar, como las Jefes de los respectivas Coordinaciones, Johana Carolina Pineda y Martha Helena Tobón, quienes de forma concordante señalaron que si no se cambia el estado asignado y recibe el acto administrativo en el aplicativo, por parte del funcionario designado en la Coordinación de Notificaciones, no podrá hacerse visible en el sistema, impidiendo gestionar la planilla de correo con la empresa respectiva. Valga mencionar, que resulta discutible, en este escenario procesal, lo expresado por Ana Sofía Martínez Castro y Johana Pineda, en el sentido de que constituyó una mala práctica, el hecho de devolver en físico un acto administrativo ante el presunto no registro en el sistema notificar, sin que se hubiese informado la novedad por correo institucional, más aún, hacer una copia del pantallazo con el error percibido, toda vez que esta aseveración provino de testigos de oídas, amén que las afirmaciones de dichas testigos reproducen simplemente lo aseverado por la disciplinada Cleves y que en rigor de la sana crítica se cuestionan por las siguientes inferencias:

.- Existe un factor subjetivo que las parcializa, habida cuenta que son jefes y compañeras de grupo, resultando lógico un sentimiento de solidaridad.

- Son testigos que gozan de una amplia experiencia y conocimiento del tema; particularmente Ana Sofía Martínez, cuando pretendió en su ampliación de testimonio, mostrar un desconocimiento del aplicativo notificar, contrario a lo expuesto en su relato inicial, cuando informó que ejercía controles del aplicativo para su debida implementación.

.- Así mismo, se cuestiona en su veracidad lo afirmado por Ana Sofía Martínez Castro y Johana Pineda, esto es, que el proceso a cargo de Notificaciones culminó con la entrega de la planilla física 602; lo cual no resulta cierto conforme al Instructivo del aplicativo notificar, la resolución que lo reglamenta y las funciones asignadas el designado para notificar en el Grupo de Notificaciones, este proceso de la notificación se deben realizar dentro de los 5 días siguientes a la fecha del acto administrativo o a la fecha de su entrega por parte del área misional, lo que comprende los trámites necesarios para surtir las notificaciones y/o comunicaciones de actos administrativos, incluidas las subsidiarias, en forma manual o sistematizada (en el aplicativo), así como era el deber de verificar las notificaciones y ejecutoria de los actos requeridos., en este caso a cargo de Ana Paola Cleves Villarraga.

c. - La prueba documental contenida en el Manual del Aplicativo Notificar, nos deja ver cómo es el proceso que Ana Paola no gestionó, veamos:

En el punto 16, el funcionario a cargo del proceso de notificaciones tiene la alternativa de corregir el proceso de forma tal que queda el registro en el sistema, seleccionando el acto a corregir, haciendo clip en el botón aceptar y modificar los campo que se quieren enmendar para así proceder nuevamente a generar planilla de remisión. Ninguna eventualidad se presentó en el escenario en que estuvo el acto en manos de Cleves, no se verificó en la trazabilidad del acto.

Ahora bien, el manual enseña que en el aplicativo existe un rol de recibir el acto, procedimiento que debe regirse como los señala en el numeral 21: "... se selecciona por el funcionario a cargo del rol RECIBIR ACTO, luego se debe ir al menú Oficios/Actos, Recibir Acto, luego de la información de detalles del acto, aparece una ventana titulada Detalles Recibe Acto, luego se verifica la información y se debe hacer clic en el botón regresar, para volver a la ventana Recepción y Reparto de Actos a Notificar y así confirmar la recepción con un OK".



POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

En ese orden de ideas y cumplidos los pasos anteriores, el punto de recibir el acto, es el proceso que le permite hacer visible el acto en el aplicativo Notificar a Carlos Molina, lo cual no sucedió, dado que ello no se ejecutó por Ana Paola Cleves, por manera que al no hacerse visible para Carlos Molina, no podía hacer la planilla de envío a la empresa de mensajería.

Sin más elucubraciones, considera este despacho que la configuración del silencio administrativo positivo proferido mediante la Resolución No. 900.052, aconteció por un actuar negligente, descuidado y despreocupado por parte de ANAN PAOLA CLEVEZ, por el hecho de no haber registrado en debida forma el acto en el aplicativo NOTIFICAR, conducta enmarcada dentro de la omisión a los deberes de cuidado que todo funcionario debe observar, desconociendo el Manual del Usuario Sistema Notificar de fecha 13 de abril de 2012, que le era de aplicación estricta dado el rol a su cargo.

Por lo tanto la anterior funcionaria, en su condición de servidora pública debió actuar bajo postulados de moralidad pública, diligencia, eficiencia, eficacia, y cuidado en sus actuaciones, es decir a partir de normas rectoras de su ejercicio, tal como lo establece la ley disciplinaria en sus artículos 5 y 22, por cuanto, al asumir sus cargos, comprometiéndose a cumplir con fidelidad y respeto sus deberes funcionales legales y constitucionales; situación que en el sub examine no se cumplió, sino que por el contrario XXXXX afrontó los principios enunciados de la función pública, que le es obligado acatar, sin justificación alguna.

De este modo, la concurrencia de los aspectos reseñados anteriormente, permiten endilgarle a XXXXX, la comisión de falta disciplinaria a título de CULPA.

#### 7. DE LA NATURALEZA DE LA FALTA

Ahora bien, la ley 734 de 2002, establece en forma taxativa el catálogo de faltas que a juicio del legislador tienen una naturaleza gravísima, de acuerdo al artículo 43 de la normatividad en comento, por lo que dentro del listado plasmado en el artículo 48, se encuentra la falta descrita en el numeral 35, la cual establece como gravísima el "Dar lugar a la configuración del silencio administrativo positivo".

Así mismo el artículo 43 al que se hace referencia, plantea en su numeral 9° que "La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave será considerada falta grave". A su vez la culpa grave es definida por el legislador en el artículo 44, cuando señala en su parágrafo que "La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones".

Con base en los parámetros legales planteados, considera este Despacho que la falta disciplinaria objeto de análisis en esta actuación, no obstante corresponder a una falta gravísima por el concepto taxativo, se ha de imputar a XXXXX, falta grave a título de culpa grave, como quiera que todos los elementos de juicio incorporados en la actuación permiten evidenciar que lo que hubo, fue una conducta caracterizada por la inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprimiría en sus actuaciones; inobservancia matizada en el caso particular por la omisión en el cumplimiento de los términos en el estatuto aduanero como ya se esbozó.

Finalmente, se debe tener muy en cuenta al momento de imponer la sanción, la aquí disciplinada no registran en su contra antecedente disciplinarios.

#### 8. DE LA SANCION POR IMPONER

Claro como quedó en el presente proceso que la investigada XXXXX es responsable de cometer la falta disciplinaria gravísima contenida en el numeral 35 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, consistente en dar lugar al silencio administrativo positivo, conforme ha sido establecido.

Así las cosas, configurados los presupuestos legales exigidos por el artículo 142 de la Ley 734 de

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

al obrar en el proceso prueba acerca de la certeza de la existencia de la falta y de la responsabilidad del involucrado, es menester proceder a determinar la sanción a imponer; para lo cual se procederá, así:

La conducta cometida por la disciplinada fue determinada como FALTA GRAVE, realizada a título de CULPA GRAVE, por lo que de conformidad con el artículo 44 del Código Disciplinario Único, a una conducta así acreditada le corresponde:

**"Artículo 44. Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones:**

1. (...)
2. (...)

**3. Suspensión, para las faltas graves culposas.**

Ahora bien, el término de suspensión de conformidad con el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, no será inferior de un mes ni superior a doce meses. Así mismo, el artículo 47 establece los criterios para la graduación de la sanción al indicar que:

**"Artículo 47. Criterios para la graduación de la sanción.**

**1. La cuantía de la multa y el término de duración de la suspensión e inhabilidad se fijarán de acuerdo con los siguientes criterios:**

- a) **Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la conducta que se investigai**
- b) **La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de la función;**
- c) **Atribuirle responsabilidad infundadamente a un tercero;**
- d) **La confesión de la falta antes de la formulación de cargos;**
- e) **Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado;**
- f) **Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien afectado con la conducta constitutiva de la falta, siempre que la devolución, restitución o reparación no se hubieren decretado en otro proceso;**
- g) **El grave daño social de la conducta;**
- h) **La afectación a derechos fundamentales;**
- i) **El conocimiento de la ilicitud;**
- j) **Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la entidad"** (Subraya fuera del texto original).

Dentro del plenario se evidencia que la servidora investigada no aparece sancionada fiscal o disciplinariamente dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la conducta por la cual se le sanciona, que no atribuyó la responsabilidad y de manera infundada a un tercero; que no hubo confesión; que no era procedente resarcir el daño o la devolución alguna; que no hubo un grave daño social con la conducta ni hubo afectación de los derechos fundamentales; que no hubo premeditación respecto de la ilicitud y que no pertenece al nivel directivo o ejecutivo de la entidad.

Así mismo se evidencia que la servidora, excepto por el caso que atañe a esta actuación, ha mostrado eficiencia en el desempeño del cargo, conforme a la calificación de su desempeño durante el año 2012, circunstancia que entonces deben tenerse en cuenta, a su favor.

En consecuencia, considera el Despacho que la sanción por imponer a la disciplinada ANA PAOLA CLEVES VILLARRAGA ha de ser la de SUSPENSIÓN en el ejercicio de su cargo, por el término de UN (1) MES, a la luz de lo dispuesto en la normatividad disciplinaria.

En mérito de lo expuesto,

**RESUELVE**

PRIMERO: DECLARAR LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA de XXXXX, identificada con la cédula de ciudadanía número XXXXX, Analista II Código 202 Grado 02 en la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la Unidad Administrativa

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-083

Especial XXXXX, para el periodo del 14 de octubre de 2014, fecha de los hechos se desempeñaba en la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la Unidad Administrativa Especial DIAN, por la conducta consignada como falta grave citada en el artículo 48, (...) numeral "...35...***Dar lugar a la configuración del silencio administrativo positivo***", formulada en la Audiencia de proceso verbal, tal como se señaló en la parte considerativa de esta decisión

SEGUNDO: como consecuencia de lo dispuesto en el numeral primero de la presente resolución, imponer como sanción, la SUSPENSION en el ejercicio del cargo, por el término de UN (1) MES, teniendo en cuenta que la conducta fue calificada como falta grave a título de culpa.

TERCERO: ABSOLVER al señor XXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.196.007, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión.

CUARTO: La presente decisión se quedará NOTIFICADA EN ESTRADOS.

QUINTO: ADVERTIR que contra la presente decisión procede el RECURSO DE APELACIÓN, por lo cual en ésta Audiencia el sujeto procesal deberá interponer y sustentar el recurso interpuesto.

SEXTO. En firme la presente decisión, COMUNICARLA en la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el artículo 174 del Código Disciplinario Único.

SEPTIMO: Una vez surtida la notificación del presente fallo, REGISTRAR La sanción disciplinaria ante la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, según lo ordena el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, en armonía con el artículo 48, numeral 57 de la misma norma.

OCTAVO: REMITIR copia de la presente decisión al nominador del procesado, para que proceda a ejecutar la sanción impuesta, de conformidad con lo establecido en el numeral 3° y parágrafo del artículo 172 del C. D. U.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE,**

*Jorge A. Moreno Ponce*

**JORGE ADRIANO MORENO PONCE**  
Subdirector de Investigaciones Disciplinarias  
UAE Agencia ITRC